



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1963433 - SP (2021/0313183-7)

RELATOR : **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
RECORRENTE : **ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA**
ADVOGADOS : **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
INTERES. : **DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"**
INTERES. : **ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA**
CRIMINAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : **JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016**
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
INTERES. : **PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS**
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : **ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA**
PÚBLICA
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR
PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1154 E TEMA 1241 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. TESES FIXADAS; RECURSOS JULGADOS.

I. CASO EM EXAME

1. *O julgamento conjunto.* Julgamento conjunto, na sistemática dos recursos repetitivos, dos temas 1154 e 1241, para fixação de tese sobre: (i) uso da natureza e quantidade de drogas para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (ii) possibilidade de utilizar a quantidade e variedade de drogas apreendidas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado.

2. *Fato relevante.* Delimitação do Tema 712 da repercussão geral (STF) como premissa: “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, quando se trata de valoração negativa na pena-base e, simultaneamente, modulação da fração do redutor.

3. *Casos representativos.* Julgamento dos REsp 1963433-SP (tema 1154), REsp 1964296-MG (tema 1154), REsp 1963489-MS (tema 1154), REsp 2059577-MG (tema 1241) e REsp 2059576-MG (tema 1241). No REsp 1963433-SP, apreensão de 294 porções de crack, total aproximado de 249,8 g, com incidência de causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; no REsp 1964296-MG, apreensão de 1,934 kg de cocaína; no REsp 1963489-MS, apreensão de 99 kg de maconha, com incidência de causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a natureza e a quantidade de drogas, isoladamente consideradas, podem servir como fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006); e (ii) saber se a quantidade e a variedade de drogas podem ser utilizadas para modular a fração de redução da minorante na terceira fase da dosimetria, e em que medida isso se compatibiliza com o Tema 712 da repercussão geral (STF) e com a vedação ao bis in idem.

5. Há duas questões adicionais em discussão: (i) saber se é possível valorar, preferencialmente, o binômio natureza-quantidade na terceira fase, deslocando-o da primeira fase sem configurar reformatio in pejus; e (ii) saber se é admissível a valoração simultânea do binômio, na primeira fase para exasperar a pena-base e, na terceira fase, para afastar a minorante, sem violação ao princípio do ne bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Firmou-se que natureza e quantidade constituem binômio incindível, devendo ser sempre valorados conjuntamente, vedada a fragmentação em vetores autônomos na dosimetria.

7. A premissa do Tema 712 (STF) impede a utilização concomitante do binômio natureza-quantidade para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para modular a fração do redutor; não alcança, porém, a hipótese de uso para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, afastar a incidência da minorante do § 4º do art. 33, o que não configura bis in idem por se tratar de fundamentos distintos.

8. Adota-se critério de especialidade: o binômio natureza-quantidade deve ser valorado preferencialmente na terceira fase para modular a fração do redutor, salvo quando a minorante não incidir, hipótese em que pode incidir na primeira fase para elevar a pena-base.

9. Não configura reformatio in pejus o deslocamento, em sede recursal de defesa, da valoração do binômio da primeira para a terceira fase, quando o tribunal passa a aplicar a minorante e utiliza a mesma circunstância apenas para modular a fração, sem aumento do quantum final da pena.

10. A apreensão de quantidade de drogas de tal modo expressiva que, por sua própria dimensão, seja incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno traficante, configura fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Fora dessa hipótese, a natureza e a quantidade das drogas podem afastar a minorante quando associadas a outros elementos do caso concreto - como alto grau de profissionalismo, sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento -, dos quais se possa inferir, mediante fundamentação concreta, a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

11. Aplicações concretas: (i) REsp 1963433-SP: mantida a negativa da minorante e o regime inicial mais gravoso, com causa de aumento do art. 40, VI; (ii) REsp 1964296-MG: afastada a minorante em razão da apreensão de 1,934 kg de cocaína, com fixação do regime inicial fechado; (iii) REsp 1963489-MS: mantida a negativa da minorante ante 99 kg de maconha e causa de aumento do art. 40, V.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Resultado do Julgamento: Teses fixadas nos temas 1154 e 1241; REsp 1963433-SP desprovido; REsp 1964296-MG provido; REsp 1963489-MS desprovido; REsp 2059577-MG e REsp 2059576-MG julgados nos termos do voto do relator, com fixação das teses.

Tese de julgamento:

1. A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas sempre de forma conjunta, como binômio incindível, vedada a aplicação separada em fases distintas da dosimetria. 2. A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas preferencialmente na terceira fase da dosimetria para modular a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, salvo quando a minorante não incidir, hipótese em que podem ser aplicadas na primeira fase para elevar a pena-base. 3. Caso a instância anterior tenha afastado a minorante e valorado o binômio na primeira fase, o tribunal, em recurso da defesa, ao aplicar o redutor, deve deslocar essa valoração para a terceira fase para modular a fração, sem configurar reformatio in pejus. 4. Não configura bis in idem considerar a natureza e a quantidade de drogas para aumentar a pena-base e, simultaneamente, como elemento fático para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; somente haverá bis in idem se o binômio for usado para elevar a pena-base e, ao mesmo tempo, para modular a fração da minorante. 5. A apreensão de quantidade de drogas de tal modo expressiva que, por sua própria dimensão, seja incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno traficante, configura fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Fora dessa hipótese, a natureza e a quantidade das drogas podem afastar a minorante quando associadas a outros elementos do caso concreto - como alto grau de profissionalismo, sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento -, dos quais se possa inferir, mediante fundamentação concreta, a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei 11.343/2006, art. 40, V e VI; Lei 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59; CP, art. 61, II, j; CP, art. 68; CP, art. 33, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVI, XXXIX e XLV; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 14, § 7º; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 666.334/AM (Tema 712), Tribunal Pleno, julgado em 03.04.2014; STJ, REsp 1.887.511/SP, Terceira Seção, julgado em 09.06.2021; STJ, HC 725.534/SP, Terceira Seção, julgado em 27.04.2022; STJ, AgRg no HC 593.509/SP, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, retomado o julgamento, A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial e fixou a seguinte tese quanto aos Temas Repetitivos n. 1241 e n. 1154: "A apreensão de quantidade de drogas de tal modo expressiva que, por sua própria dimensão, seja incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno traficante, configura fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Fora dessa hipótese, a natureza e a quantidade das drogas podem afastar a minorante quando associadas a outros elementos do caso concreto - como alto grau de profissionalismo, sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento -, dos quais se possa inferir, mediante fundamentação concreta, a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 18 de junho de 2026.

Ministro Messod Azulay Neto
Relator

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO**

Número Registro: 2021/0313183-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.963.433 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 15007957820198260126

PAUTA: 08/05/2025

JULGADO: 14/05/2025

RelatorExmo. Sr. Ministro **MESSOD AZULAY NETO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMAN THOMÉ

Secretário

Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA : MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS
RICARDO MORARI PEREIRA
PEDRO TENERELLO - PR032270
INTERES. : GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR PÚBLICO
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA PÚBLICA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator, após pedido do Procurador-Geral do
Estado de Minas Gerais.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5421644941656181865@ 2021/0313183-7 - REsp 1963433



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1963433 - SP (2021/0313183-7)

RELATOR : **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA
CRIMINAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
INTERES. : GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA
PÚBLICA
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR
PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1154 E TEMA 1241 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. TESES FIXADAS; RECURSOS JULGADOS.

I. CASO EM EXAME

1. *O julgamento conjunto.* Julgamento conjunto, na sistemática dos recursos repetitivos, dos temas 1154 e 1241, para fixação de tese sobre: (i) uso da natureza e quantidade de drogas para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (ii) possibilidade de utilizar a quantidade e variedade de drogas apreendidas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado.

2. *Fato relevante.* Delimitação do Tema 712 da repercussão geral (STF) como premissa: “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, quando se trata de valoração negativa na pena-base e, simultaneamente, modulação da fração do redutor.

3. *Casos representativos.* Julgamento dos REsp 1963433-SP (tema 1154), REsp 1964296-MG (tema 1154), REsp 1963489-MS (tema 1154), REsp 2059577-MG (tema 1241) e REsp 2059576-MG (tema 1241). No REsp 1963433-SP, apreensão de 294 porções de crack, total aproximado de 249,8 g, com incidência de causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; no REsp 1964296-MG, apreensão de 1,934 kg de cocaína; no REsp 1963489-MS, apreensão de 99 kg de maconha, com incidência de causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a natureza e a quantidade de drogas, isoladamente consideradas, podem servir como fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006); e (ii) saber se a quantidade e a variedade de drogas podem ser utilizadas para modular a fração de redução da minorante na terceira fase da dosimetria, e em que medida isso se compatibiliza com o Tema 712 da repercussão geral (STF) e com a vedação ao bis in idem.

5. Há duas questões adicionais em discussão: (i) saber se é possível valorar, preferencialmente, o binômio natureza-quantidade na terceira fase, deslocando-o da primeira fase sem configurar reformatio in pejus; e (ii) saber se é admissível a valoração simultânea do binômio, na primeira fase para exasperar a pena-base e, na terceira fase, para afastar a minorante, sem violação ao princípio do ne bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Firmou-se que natureza e quantidade constituem binômio incindível, devendo ser sempre valorados conjuntamente, vedada a fragmentação em vetores autônomos na dosimetria.

7. A premissa do Tema 712 (STF) impede a utilização concomitante do binômio natureza-quantidade para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para modular a fração do redutor; não alcança, porém, a hipótese de uso para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, afastar a incidência da minorante do § 4º do art. 33, o que não configura bis in idem por se tratar de fundamentos distintos.

8. Adota-se critério de especialidade: o binômio natureza-quantidade deve ser valorado preferencialmente na terceira fase para modular a fração do redutor, salvo quando a minorante não incidir, hipótese em que pode incidir na primeira fase para elevar a pena-base.

9. Não configura reformatio in pejus o deslocamento, em sede recursal de defesa, da valoração do binômio da primeira para a terceira fase, quando o tribunal passa a aplicar a minorante e utiliza a mesma circunstância apenas para modular a fração, sem aumento do quantum final da pena.

10. A apreensão de quantidade de drogas de tal modo expressiva que, por sua própria dimensão, seja incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno traficante, configura fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Fora dessa hipótese, a natureza e a quantidade das drogas podem afastar a minorante quando associadas a outros elementos do caso concreto - como alto grau de profissionalismo, sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento -, dos quais se possa inferir, mediante fundamentação concreta, a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

11. Aplicações concretas: (i) REsp 1963433-SP: mantida a negativa da minorante e o regime inicial mais gravoso, com causa de aumento do art. 40, VI; (ii) REsp 1964296-MG: afastada a minorante em razão da apreensão de 1,934 kg de cocaína, com fixação do regime inicial fechado; (iii) REsp 1963489-MS: mantida a negativa da minorante ante 99 kg de maconha e causa de aumento do art. 40, V.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Resultado do Julgamento: Teses fixadas nos temas 1154 e 1241; REsp 1963433-SP desprovido; REsp 1964296-MG provido; REsp 1963489-MS desprovido; REsp 2059577-MG e REsp 2059576-MG julgados nos termos do voto do relator, com fixação das teses.

Tese de julgamento:

1. A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas sempre de forma conjunta, como binômio incindível, vedada a aplicação separada em fases distintas da dosimetria. 2. A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas preferencialmente na terceira fase da dosimetria para modular a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, salvo quando a minorante não incidir, hipótese em que podem ser aplicadas

na primeira fase para elevar a pena-base. 3. Caso a instância anterior tenha afastado a minorante e valorado o binômio na primeira fase, o tribunal, em recurso da defesa, ao aplicar o redutor, deve deslocar essa valoração para a terceira fase para modular a fração, sem configurar reformatio in pejus. 4. Não configura bis in idem considerar a natureza e a quantidade de drogas para aumentar a pena-base e, simultaneamente, como elemento fático para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; somente haverá bis in idem se o binômio for usado para elevar a pena-base e, ao mesmo tempo, para modular a fração da minorante. 5. A apreensão de quantidade de drogas de tal modo expressiva que, por sua própria dimensão, seja incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno traficante, configura fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Fora dessa hipótese, a natureza e a quantidade das drogas podem afastar a minorante quando associadas a outros elementos do caso concreto - como alto grau de profissionalismo, sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento -, dos quais se possa inferir, mediante fundamentação concreta, a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei 11.343/2006, art. 40, V e VI; Lei 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59; CP, art. 61, II, j; CP, art. 68; CP, art. 33, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVI, XXXIX e XLV; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 14, § 7º; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 666.334/AM (Tema 712), Tribunal Pleno, julgado em 03.04.2014; STJ, REsp 1.887.511/SP, Terceira Seção, julgado em 09.06.2021; STJ, HC 725.534/SP, Terceira Seção, julgado em 27.04.2022; STJ, AgRg no HC 593.509/SP, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.

RELATÓRIO

Na sessão do dia 12 de fevereiro de 2025, a Terceira Seção, ao apreciar o tema 1241 da sistemática dos recursos repetitivos, decidiu suspender o julgamento para que fosse viabilizada a análise conjunta com o tema 1154, de minha relatoria (certidão de julgamento de fl. 453 dos autos do Recurso Especial 2059577-MG).

O tema 1154 tem como representativos da controvérsia os autos dos Recursos Especiais 1963433-SP, 1963489-MS, 1964296-MG e o tema 1241 tem como representativos os autos dos Recursos Especiais 2059576-MG e 2059577-MG.

Passo, então, ao relatório de cada um dos processos afetados ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil e dos arts. 256 ao 256-X do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

1) Recurso Especial 1963433-SP, tema 1154

O recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, indica como violados os arts. 33, §§ 2º, “a”, “b” e “c”, e 3º, e 44, I a III, e § 2º, do Código Penal, bem como os arts. 22, § 1º, e 42 da Lei 11.343/2006. A defesa argumenta, em síntese, contra a negativa da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o estabelecimento de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sobre a questão relativa à violação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a defesa pontua que a quantidade e a natureza dos entorpecentes não seriam circunstâncias idôneas para justificar o afastamento do redutor previsto no referido dispositivo. Aduz, ainda, que essas circunstâncias serviriam, no máximo, para balizar a fração da redução da pena a ser aplicada em conjunto com as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Relativamente ao regime inicial de cumprimento de pena, argumenta que não se pode admitir regime mais gravoso que o recomendado para a pena apenas com base no entendimento de que se trata de delito mais grave que os demais. Acrescenta, por fim, que, realizado o reparo quanto à fração do privilégio, é viável a substituição da pena por restritiva de direitos (fls. 259-275 dos autos do REsp 1963433).

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo provimento do recurso especial com o reconhecimento da impossibilidade de se considerar a natureza e quantidade do entorpecente apreendido como elementos suficientes para, por si sós, ensejarem a conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e, assim, obstar, indevidamente, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (fls. 379-383 dos autos do REsp 1963433).

2) Recurso Especial 1964296-MG, tema 1154

O recurso especial, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, indica a violação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. O Ministério Público argumenta que a elevada quantidade de entorpecentes apreendida permitiria presumir que o agente é dedicado a atividades criminosas. Alega também que os arts. 33, § 2º, “a” e “b”, e 59, *caput*, II, do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006 foram contrariados. Pondera, por fim, que deveria ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e fixado o regime inicial fechado de cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 290-321 dos autos do REsp 1964296).

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso especial, apenas, para que fosse estabelecido o regime fechado, com a manutenção da minorante do tráfico privilegiado, em razão da impossibilidade de se considerar, por si sós, a natureza e quantidade do entorpecente, para obstar a incidência da redutora (fls. 448-454 dos autos do REsp 1964296).

3) Recurso Especial 1963489-MS, tema 1154

O recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, apontou como violado o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em razão da negativa à causa especial de diminuição de pena, com base na presunção derivada da quantidade de droga apreendida. As razões recursais aduzem que a fração de diminuição do 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 deve ser fixada no patamar máximo, já que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, comportamento e consequências, teriam sido favoráveis. A parte pondera, por fim, quanto ao regime de cumprimento de pena, que teria direito ao regime aberto e à substituição da pena por restritiva de direitos (fls. 357-369 dos autos do REsp 1963489).

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do recurso especial (fls. 466-474 dos autos do REsp 1963489).

4) Recurso Especial 2059577, Tema 1241

O recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, aponta como violados os arts. 59 e 68 do Código Penal e o art. 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que seria desproporcional a aplicação da fração mínima de 1/6, relativa à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, exclusivamente em razão da elevada quantidade de entorpecentes (fls. 263-270 dos autos do REsp 2059577).

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do recurso especial (fls. 364-368 autos do REsp 2059577).

5) Recurso Especial 2059576, Tema 1241

O recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação n. 1.0024.20.141542-9/001, afirma que não há provas da

autoria delitiva e, sucessivamente, aponta violação ao art. 42 e § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque a quantidade de drogas apreendida não poderia ser utilizada para impedir a aplicação da fração máxima de 2/3 na terceira fase da dosimetria da pena. (fls. 415-427).

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do recurso especial (fls. 522-527).

São os relatórios dos recursos afetados para análise conjunta.

VOTO

1) Contexto do julgamento

Tinha, em meu gabinete, controvérsia afetada à sistemática dos recursos repetitivos, cadastrada como tema 1154, que, com aparente objetivo de reafirmação da jurisprudência atual, conta com a seguinte delimitação: “isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado”.

Acontece que, recentemente, foi levado a julgamento perante a Terceira Seção o tema 1241 com controvérsia interrelacionada com a temática do tema 1154: “possibilidade de utilização da quantidade e variedade de drogas apreendidas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006”.

Iniciado o julgamento, muito embora a controvérsia do tema 1241 estivesse limitada ao debate sobre a utilização do vetor quantidade e variedade na modulação da fração de redução da minorante, o Ministro relator, Ribeiro Dantas, dada a interrelação entre as matérias, apresentou proposta de tese que, de certo modo, estendia o seu objeto e aglutinava os referidos temas, nos seguintes termos: “a quantidade da droga, por si só, não pode afastar a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, contudo, pode servir de parâmetro para modular a fração de diminuição da pena entre 1/6 e 2/3”.

O colegiado, então, suspendeu o julgamento e convencionou que os temas 1154 e 1241 fossem analisados em conjunto, razão por que entendi por bem submeter voto único sobre as duas controvérsias, a de minha relatoria, tema 1154, e a de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, tema 1241.

Minha manifestação, aqui, portanto, assume a natureza de voto do relator para o tema 1154 e voto-vista para o tema 1241.

A aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é, sem dúvida, uma das temáticas mais recorrentes nas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça. E, especialmente em razão da subjetividade dos requisitos de não dedicação às atividades criminosas e de não integração a organizações criminosas, esta Corte, assim como o Supremo Tribunal Federal, são instados a revisar e interpretar toda sorte de fundamentações utilizadas na aplicabilidade da figura privilegiada pelos diversos tribunais do país.

A opção legislativa pela utilização de requisitos com conceitos abertos induz, de fato, inúmeros contextos possíveis e daí a dificuldade com a matéria e a imensa quantidade de processos submetidos a julgamento perante os Tribunais Superiores. E são, realmente, inúmeras as controvérsias acerca da aplicabilidade do instituto, muitas vezes tratadas de forma contraditória e descontínua pela jurisprudência, como por exemplo: (a) a impossibilidade de utilização de inquéritos e ações penais em andamento como fatores impeditivos; (b) o uso de registros de diversas viagens internacionais incompatíveis com a condição financeira declarada como critério para afastamento do redutor; (c) o contexto de apreensão de petrechos para traficância como circunstância fática apta à presunção de dedicação às atividades criminosas; (d) as conversas no celular do acusado indicando comércio de drogas como vetor de afastamento, ou não, da minorante; (e) a droga apreendida em contexto de transporte intermunicipal e a presunção de integração a organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas; (f) os veículos preparados ou com fundos falsos para o transporte do entorpecente e a presunção de dedicação ou de integração a organizações voltadas para o tráfico; a existência de registro de atos infracionais pretéritos como circunstância de afastamento do privilégio; entre outras.

Dentre todas essas questões, as discussões sobre a natureza e quantidade da droga como vetor de negativação da primeira fase da dosimetria, como elementos para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou, ainda, para modular a respectiva fração de diminuição da pena são das mais comuns no cotidiano deste Tribunal Superior e, igualmente, complexas, dado o largo espectro de possibilidades concretas que delas podem derivar.

Nunca escondi minha perplexidade com a matéria. São recorrentes minhas manifestações, especialmente na Quinta Turma, de contrariedade a casos concretos que reputo inadmissíveis. São hipóteses em que nos deparamos com grandes quantidades de entorpecentes – centenas de quilos, toneladas -, das mais variadas naturezas, apreendidos

em contexto de logística e armazenamento sofisticados, que, com base no entendimento atual da Terceira Seção, em muitas vezes, incide a figura do tráfico privilegiado. E, assim, resulta em penas que não cumprem a devida função dissuasória.

Minha posição sempre caminhou no sentido de que grandes quantidades ou alta diversidade de drogas poderiam indicar, sim, a depender do caso concreto, por si, o afastamento do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343 de 2006, sem a necessidade de conjugação com outros elementos concretos. Na minha compreensão, a aplicação da causa de diminuição de pena em situações de apreensão de grandes quantidades de drogas traduz e fomenta a impunidade de um crime central no combate à violência organizada em nosso país.

Não se pode perder de vista que, segundo dados colhidos no Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública, SINESP, mantido pelo Ministério da Justiça, temos, em média, aproximadamente quinhentas ocorrências de tráfico de drogas por dia no Brasil. São apreendidos, diariamente, quase quatro mil quilos de maconha e aproximadamente quatrocentos quilos de cocaína.

Segundo o Mapa da Segurança, o Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta que o Brasil é rota estratégica para o tráfico internacional de drogas, principalmente, dos maiores produtores de cocaína do mundo: Bolívia, Peru e Colômbia. De 2013 a 2017, a Polícia Federal apreendeu em média, trinta e oito toneladas de cocaína e insumos por ano. E, de 2018 a 2023, o número subiu para quase noventa toneladas por ano.

O cenário é alarmante. E, obviamente, sem deixar de lado a situação, igualmente alarmante, do sistema carcerário brasileiro - que, como se afirma reiteradamente, vive, há muito tempo, em um estado de coisas inconstitucional -, é preciso fazer a adequada interpretação da aplicabilidade do redutor contido no §4º do art. 33 da Lei 11.343 de 2006, tendo em consideração todas essas variáveis e, especialmente, a teleologia do dispositivo em exame.

Antes de passar, enfim, propriamente para o exame do mérito e para facilitar os trabalhos deste julgamento, faço um registro. O voto que submeto, nesta ocasião, faz coro ao voto-vista relativo ao Tema 1241, disponibilizado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no sistema dos Ministros, mas não lido na sessão de julgamento anterior, e apresenta razões de decidir semelhantes, tanto em relação ao tema 1241, como ao tema 1154, com proposta de tese muito semelhante, apenas com algumas, pouquíssimas, propostas de alteração.

1) Um pressuposto: o Tema da Repercussão Geral 712 do Supremo Tribunal Federal

Parece indispensável que, inicialmente, seja analisada a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, sobre a matéria - tema 712 -, de modo que os julgamentos dos temas 1154 e 1241, por este Superior Tribunal de Justiça, não colidam com o tema já definido pelo Supremo, em atenção e respeito à estabilidade, integridade e coerência da sistemática de padronização decisória de natureza vinculante dos precedentes em repercussão geral – *stare decisis* vertical.

No julgamento do *leading case*, Agravo em Recurso Extraordinário 666334, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou, por maioria, tese, na sistemática da repercussão geral, no sentido de que “(a)s circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

No caso concreto que deu origem à tese, a controvérsia consistia no exame da viabilidade da consideração da quantidade e natureza da droga apreendida como vetor negativo na primeira fase da dosimetria e, também, na terceira fase, como fator de modulação da fração do redutor da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

A tese fixada em repercussão geral pressupunha, portanto, essa circunstância específica. O reconhecimento do *bis in idem* ficou, assim, pelo menos em caráter vinculante, restrito à hipótese de utilização simultânea da quantidade e natureza da droga como circunstância desfavorável na primeira etapa da dosimetria e como elemento modulador da fração de redução da causa de diminuição de pena na terceira etapa.

Assim, visto por outra perspectiva, ficou assentado que configura *bis in idem* utilização simultânea da quantidade e natureza da droga como circunstância desfavorável na primeira etapa da dosimetria e como elemento modulador da fração de redução da causa de diminuição de pena na terceira etapa.

Entendo, por conseguinte, que essa é a baliza e o pressuposto para o julgamento desses dois temas repetitivos: 1154 e 1241. Seja qual for a posição adotada por esta Terceira Seção, não se poderá fixar teses que entrem em contradição com aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 712 da repercussão geral, isto é, não se poderá chegar à conclusão de que quantidade e natureza podem incidir simultaneamente na primeira fase, como vetor de exasperação, e na terceira, como fator de modulação da fração de redução.

Em sentido contrário, então, anoto, desde logo, que, no Tema 712, o Supremo não analisou a possibilidade de utilização simultânea da circunstância quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria e, na terceira fase, como fator de afastamento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343, 2006.

2) Histórico da matéria na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Como mencionado pelo Ministro relator, Ribeiro Dantas, e pelo vistor, Ministro Rogério Schietti Cruz, nos autos do Recursos Especiais que demarcam o Tema 1241, nesta Corte, a compreensão atual acerca da aplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 se assenta, fundamentalmente, em dois precedentes da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça.

Nenhum dos dois precedentes julgado na sistemática dos recursos repetitivos.

No primeiro julgado, de 2021, nos autos do Recurso Especial 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, a Terceira Seção estabeleceu, em síntese, as seguintes diretrizes: (a) o vetor natureza e quantidade são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base; (b) a utilização supletiva na terceira fase da dosimetria para afastamento do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor estiver conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, conjuntamente, caracterizem a dedicação a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa; e (c) podem ser utilizadas para a modulação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59, Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa da dosimetria da pena.

Mais detalhadamente, cito alguns trechos da ementa:

[...]

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

[...]

(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021)

No segundo precedente, de 2022, nos autos do Habeas Corpus 725.534/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, a Terceira Seção revisitou, em parte, as diretrizes firmadas no julgamento anterior e passou a adotar o entendimento, em suma, de que a circunstância quantidade e natureza pode servir de fundamento para a exasperação da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, desde que, para a modulação, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

Transcrevo os trechos mais relevantes da ementa do julgado:

[...]

2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro João Otávio De Noronha (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original).

3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria.

5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado:

Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

[...]

8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga

apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (RHC 138117 AgR, Relatora: Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021).

[...]

(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022)

A partir desse contexto jurisprudencial, portanto, foram afetados à sistemática dos repetitivos os temas 1154 e 1241. E, como dito anteriormente, o Ministro Ribeiro Dantas trouxe o Tema 1241, para reafirmação do entendimento atual, a julgamento perante esta Terceira Seção para consolidação da tese na sistemática dos recursos repetitivos, nos seguintes termos: "a quantidade da droga, por si só, não pode afastar a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, contudo, pode servir de parâmetro para modular a fração de diminuição da pena entre 1/6 e 2/3".

3) Interpretação da quantidade e natureza, por si, como fatores de afastamento do privilégio

Estabelecido o pressuposto e o contexto jurisprudencial sobre o tema, passo, então, ao que entendo ser a interpretação mais adequada do §4º do art. 33 e do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Começo com a fixação de uma premissa fundamental para a análise: natureza e quantidade, previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, constituem circunstância única. Não se pode, pois, de acordo com o que vem sendo decidido, valorar quantidade e natureza de forma separada, seja na mesma etapa, seja em etapas diferentes da dosimetria da pena. Não são vetores judiciais autônomos, mas binômio incindível, a ser avaliado sempre conjuntamente.

Nesse sentido, faço referência a alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal e das Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça: RHC 169343 AgR, Relatora: Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, Processo Eletrônico DJe-125 Divulg 25-06-2021 Public 28-06-2021; REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022; AgRg no AREsp n. 2.755.915/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, Djen de 17/12/2024.

Entendo que é relevante que esse ponto, sobre a unicidade da circunstância natureza e quantidade, conste expressamente da tese a ser fixada para que se evite, ou para que se encerre, a prática de separação do vetor em dois como justificativa para dosimetrias em desacordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Passando para a interpretação da aplicação dos dispositivos, como já mencionado anteriormente, a opção do legislador por conceitos abertos para configuração da incidência da causa de diminuição de pena gera inúmeros contextos e uma grande dificuldade de uniformização da interpretação.

Parece relevante, então, partir de um pressuposto básico da redação legislativa do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006: a aplicação da figura privilegiada é exceção, e não regra. Depende da configuração de requisitos específicos e não poderia, ou não deveria, ser aplicada de forma irrestrita e como se fosse a regra geral. A interpretação teleológica da norma leva, invariavelmente, à conclusão de que a minorante se destina ao traficante eventual, ao pequeno traficante, às pessoas não envolvidas, ainda que indiretamente, a organizações voltadas ao tráfico de drogas como meio de vida profissional.

Assim, como venho reiteradamente me posicionando, entendo ser inadequada a aplicação do redutor em contextos de apreensão de grandes quantidades e variedades (natureza) de drogas. Não se pode imaginar, nem na mais remota das possibilidades, que não exista uma organização criminosa por trás de uma grande apreensão de entorpecentes. Inviável a interpretação de que quem carrega consigo centenas ou milhares de quilos de drogas não esteja associado a uma organização criminosa ou não se dedique a atividades criminosas. Para que volumes grandes de drogas, armazenados e transportados com profissionalismo, sejam confiados a alguém, a presunção é de que essa pessoa tenha alguma uma relação, ainda que indireta, com o tráfico de drogas, o que, por si, com as vênias dos que pensam em sentido contrário, afasta a excepcionalidade do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em resumo, a partir do contexto normativo, não parece acertada a interpretação de que alguém que seja flagrado com grandes quantidades de drogas seja considerado como uma pessoa não envolvida com o tráfico de drogas organizado, mas um pequeno traficante ou um traficante eventual.

Faço, então, coro ao que defendeu o Ministro Rogério Schietti Cruz em seu voto vista relativo ao Tema 1241 e, também, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.887.511/SP, oportunidade em que sua excelência defendeu a ideia de que “nenhuma pessoa sozinha, salvo raríssimos casos de indivíduos bilionários, conseguiria adquirir tamanha quantidade de drogas. É preciso haver uma organização por trás dela,

toda uma estrutura, de maneira que seria uma negação da realidade não afastarmos o benefício nessas situações”.

De fato, parece que, apesar das melhores intenções deste Tribunal Superior, a compreensão atual sobre a matéria, ao completar os vagos conceitos legislativos, nega a realidade e, de certa forma, fomenta essa indesejável atividade criminosa.

4) Interpretação da natureza e quantidade como vetor de negatização da primeira fase e fator de afastamento do tráfico privilegiado

Retomo, neste ponto, a ideia de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 712 da repercussão geral ficou restrito à hipótese de utilização simultânea da quantidade e natureza da droga como circunstância desfavorável na primeira etapa da dosimetria e como elemento modulador da fração de redução da causa de diminuição de pena na terceira etapa. Logo, nesse contexto específico, “(a)s circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (ARE 666334 RG, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito Dje-084 divulg 05-05-2014 public 06-05-2014).

Como mencionado anteriormente, o Supremo não analisou, contudo, a possibilidade de utilização simultânea da circunstância quantidade e natureza como vetor de negatização na primeira fase da dosimetria e, na terceira fase, como fator de afastamento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343, 2006.

Reiterado esse pressuposto, na mesma linha do voto-vista do Ministro Rogério Schietti Cruz, na oportunidade da submissão do tema 1241, entendo que a utilização simultânea do vetor quantidade e natureza na exasperação da pena na primeira fase, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, e com fator de impedimento para aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 não implica bis in idem.

O princípio da proibição do *bis in idem*, ou *ne bis in idem* ou, ainda, *non bis in idem*, constitui um dos mais relevantes postulados de natureza material do Direito Penal e Processual Penal, essencialmente, por estabelecer um limite ao poder punitivo do Estado: o impedimento de mais de uma punição penal pelo mesmo fato.

A proibição do *bis in idem* se manifesta em dispositivos legais e constitucionais, tais como: no âmbito interno, de forma indireta, os art. 5º, incisos XXXVI, XXXIX e XLV, da Constituição, e os arts. 8º e 42 do Código Penal; no âmbito

internacional, de forma mais direta, o art. 14, §7º, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Político, e o art. 8º, §4º, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Sobre o conteúdo jurídico do princípio do *non bis idem*, Luiz Regis Prado, citando Estrella Escuchuri Aisa, anota que

“(o) conteúdo penal substancial do *ne bis in idem* exige a concorrência da denominada tríplice identidade entre sujeito (identidade subjetiva ou de agentes), fato (identidade fática) e fundamento (necessidade de se evitar a dupla punição, quando o desvalor total do fato é abarcado por apenas um dos preceitos incriminadores) [...]” (Op. cit Escuchuri Aisa, E. Teoría de concurso de leyes y de delitos, p. 174 e ss. in Prado, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral. 22 ed. Londrina: Editora Thoth, 2024. p.110)

Na aplicação simultânea da circunstância quantidade e natureza de drogas na primeira fase da dosimetria, como vetor de negatificação, e, na terceira etapa, como fator de afastamento do redutor, os fundamentos são claramente diferentes. A incidência do binômio na primeira fase da dosimetria denota o grau aumentado de intensidade da lesão ao bem jurídico tutelado. Por sua vez e de forma diversa, a circunstância da quantidade e natureza, na terceira fase, confere base fática, elemento de realidade, para a interpretação dos requisitos subjetivos da figura privilegiada, ou seja, é o que permite a concretização dos conceitos abertos relativos ao envolvimento do agente com organizações criminosas ou sua dedicação a atividades criminosas, de modo a se verificar o preenchimento de requisitos para a concessão do benefício, repito, excepcional.

Assim, ao tempo que, na primeira fase, a circunstância induz uma consequência de incremento da pena, na terceira etapa, serve como fator de preenchimento de requisitos para a concessão de um benefício previsto em lei. Não se verifica, então, duplo aumento de pena com base no mesmo fato ou fundamento jurídico.

Não se está diante, portanto, de uma hipótese de aplicação da proibição de *bis in idem*.

Registro, ainda, que, em relação aos requisitos objetivos para a concessão do tráfico privilegiado, não se discute a aplicação do postulado do *ne bis in idem* a situações semelhantes. Os maus antecedentes podem ser valorados negativamente na primeira fase, nos termos do art. 59, Código Penal, e, por expressa previsão do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, simultaneamente, afastar o redutor de pena. Igualmente, a reincidência é valorada na segunda etapa da dosimetria e, ao mesmo tempo, utilizada, na terceira fase, para impedir a aplicação da figura privilegiada. Além de não haver nenhuma dúvida sobre

esses pontos, é possível, inclusive, encontrar na jurisprudência manifestações expressas que afirmam claramente a não incidência da proibição da dupla punição.

Cito como exemplo:

[...]

3. Não há que se falar em bis in idem pela exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), bem como pelo afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Como já enfatizado, trata-se de previsão legal que evidencia apenas a necessidade de individualização da pena, ante a maior gravidade da conduta. No caso, a paciente possui maus antecedentes e é reincidente, o que justifica a exasperação da pena na primeira e na segunda fases, bem como afasta a incidência da figura do tráfico privilegiado.

[...]

(AgRg no HC n. 593.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020)

Não se tem dúvida, também, de que a condenação anterior por associação para o tráfico de drogas, crime autônomo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, afasta a aplicação do tráfico privilegiado, sem que exista qualquer discussão jurisprudencial sobre uma eventual dupla valoração negativa vedada pelo princípio do *ne bis in idem*.

Repito, aqui em minha manifestação, mais um bom exemplo dado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em seu voto-vista relativo ao Tema 1241, por esclarecer bem a matéria e o tratamento dispensado pelo Código Penal às figuras privilegiadas. No delito de furto, se o criminoso é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, aplica-se o privilégio, na forma do §2º do art. 155 do Código Penal. Se o entendimento atual sobre a figura do tráfico privilegiado fosse aplicado ao furto privilegiado, poder-se-ia ter uma situação em que, se um agente furtasse uma grande quantia e, em razão disso, o juízo exasperasse a pena-base com esse fundamento (grande quantia), por ter sido usada na primeira fase, não poderia servir de fundamento para afastar o privilégio do furto, sob pena do *ne bis in idem*.

Não existe, portanto, nenhuma razão para que o tratamento do privilégio no tráfico seja diferente.

Enfim, reitero minha perplexidade quanto ao atual entendimento da Terceira Seção. Ao não se poder utilizar a circunstâncias quantidade e natureza para afastar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, são diversos os casos de grandes quantidades de entorpecentes - quilos, toneladas -, das mais variadas naturezas, apreendidos em contexto de logística e armazenamento sofisticados, que, com base nesse

entendimento, em muitas vezes, incide a figura do tráfico privilegiado. E, assim, acaba por resultar em penas que não cumprem a devida função dissuasória e não cumprem o comando legislativo da forma apropriada.

Entendo, a partir dessas premissas, que a interpretação adequada dos dispositivos afetos à matéria deve se dar no sentido da possibilidade de utilização simultânea da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e afastar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343 de 2006, na terceira etapa.

5) Metodologia de aplicação do entendimento e modulação da fração

Superada a questão acerca da legalidade da utilização simultânea do vetor quantidade e natureza para exasperar a pena-base, na primeira fase, e afastar o redutor, na terceira fase, passo a examinar a hipótese em que o redutor não é afastado.

Aqui, temos a aplicação direta do pressuposto fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 712 da repercussão geral: “(a)s circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. Logo, não afastada a causa de diminuição de pena, surge a possibilidade de utilização da circunstância natureza e quantidade para exasperar a pena-base, na primeira etapa, ou modular a fração de diminuição na terceira fase.

De forma pragmática e para facilitar os trabalhos deste julgamento, alinho-me ao entendimento externado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, que, nos autos do Recurso Especial 2.059.577, defendeu que a metodologia extraída de uma leitura sistêmica do ordenamento sobre a matéria implica a adoção do critério da especialidade e, portanto, aplicação sempre da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena, isto é, quando a circunstância constitui elemento da terceira fase, não pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria. Por conseguinte, se utilizada para modular a fração de redução da causa de diminuição de pena, a circunstância quantidade e natureza não poderá ser utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase, sob pena, aí sim, de *bis in idem*.

Acolho, portanto, a proposta de que a natureza e a quantidade de drogas sejam valoradas sempre na terceira fase da dosimetria da pena, exceto nos casos em que o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 for afastado, hipóteses em que, como visto anteriormente, poderá o vetor quantidade e natureza incidir simultaneamente na primeira fase como fator de exasperação da pena-base.

Filio-me, igualmente, ao entendimento de que não constitui *reformatio in pejus* a hipótese de o tribunal, em recurso da defesa, decidir aplicar o redutor - não aplicado na instância inferior - e utilizar a circunstância quantidade e natureza para modular a fração da causa de diminuição. Isso porque, como me manifestei no julgamento do Tema 1214, naquela ocasião em voto-vista, não constitui reforma em prejuízo do acusado a redesignação da classificação de um fato valorado negativamente, desde que não revele incremento da pena.

6) Proposta de tese

Adotando essas premissas teóricas, manifesto minha adesão às propostas trazidas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, com pequenas alterações e com acréscimo de um item, nos seguintes termos:

6.1) A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas sempre de forma conjunta. Não é possível, portanto, realizar a aplicação separada como se fossem elementos autônomos;

6.2) A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas preferencialmente na terceira fase da dosimetria da pena, para modular a fração de diminuição, salvo quando não incidir na hipótese a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, caso em que essa circunstância poderá ser aplicada na primeira etapa da dosimetria para aumentar a pena-base;

6.3) Caso a instância anterior tenha afastado a incidência da minorante e valorado a natureza e a quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, mas o tribunal, em recurso da defesa, decida aplicar o redutor, deverá, se possível, deslocar a aplicação dessa circunstância para a terceira fase, a fim de modular a fração de diminuição, o que não configura *reformatio in pejus*.

6.4) Não configura *bis in idem* considerar a quantidade e a natureza de drogas como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, como elemento fático indicador de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa para afastar a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Somente haverá *bis in idem* se essa circunstância for usada, simultaneamente, para aumentar a pena-base e para modular a fração de redução da pena na terceira fase.

6.5) A apreensão de quantidade de drogas de tal modo expressiva que, por sua própria dimensão, seja incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno

traficante, configura fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Fora dessa hipótese, a natureza e a quantidade das drogas podem afastar a minorante quando associadas a outros elementos do caso concreto - como alto grau de profissionalismo, sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento -, dos quais se possa inferir, mediante fundamentação concreta, a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

7) Casos concretos e dispositivos

Passo, enfim, às soluções para os casos concretos a partir dos parâmetros estabelecidos pela tese proposta com os respectivos dispositivos.

7.1) Recurso Especial 1963433-SP, tema 1154

Na primeira fase, mantenho os critérios empregados pela instância originária, que fixou a pena-base no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho os critérios empregados pela instância originária, que reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa, e manteve a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em atenção à vedação enunciada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, mantenho os critérios empregados pela instância originária, que afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. A apreensão de 294 (duzentas e noventa e quatro) porções de crack, com peso aproximado de 227,62g (duzentos e vinte e sete gramas e sessenta e dois centigramas) e 1 (uma) porção da mesma droga, com peso aproximado de 22,18g (vinte e dois gramas e dezoito centigramas), indica que réu não é um mero traficante eventual, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa. Mantenho o reconhecimento da causa especial de aumento de pena do inciso VI do art.40 da Lei 11.343/2006, ficando a pena definitiva mantida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Muito embora na primeira fase da dosimetria a pena-base tenha sido estipulada no mínimo legal, a circunstância judicial negativa do artigo 42 da Lei 11.343/2006 foi valorada na terceira etapa da dosimetria da pena, autorizando o estabelecimento do regime inicial mais gravoso subsequente, em atenção ao disposto no art. 33, §3º, e 59 do Código Penal.

Assim, nego provimento ao recurso especial.

7.2) Recurso Especial 1964296-MG, tema 1154

Na primeira fase, mantenho os critérios empregados pela instância originária, que fixou pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho os critérios empregados pela instância originária, que não reconheceu a presença de atenuantes nem agravantes, ficando a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, afasto a incidência da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. A apreensão de 1,934 Kg (um quilo novecentos e trinta e quatro gramas) de cocaína indica que o réu não é mero traficante eventual, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa, passando a pena definitiva para 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Estabeleço, então, o regime inicial fechado, em atenção o disposto no art. 33, §3º, e 59 do Código Penal.

Assim, dou provimento ao recurso especial para redimensionar a pena para 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação.

7.3) Recurso Especial 1963489-MS, tema 1154

Na primeira fase, mantenho os critérios empregados pela instância originária, que fixou pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho os critérios empregados pela instância originária, que compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “j”, Código Penal, ficando a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho os critérios empregados pela instância originária, que afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. A apreensão de 99 Kg (noventa e nove quilos) de maconha indica que o réu não é um mero traficante eventual, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas

ou integração à organização criminosa. Mantenho o reconhecimento da causa especial de aumento de pena do inciso V do art. 40 da Lei 11.343/2006, ficando mantida a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Mantenho, então, o regime inicial fechado, em atenção o disposto no art. 33, §3º, e 59 do Código Penal.

Assim, nego provimento ao recurso especial.

7.4) Recurso Especial 2059577, Tema 1241

Acompanho o Ministro Ribeiro Dantas em relação à solução para o caso concreto, mas divirjo para fixar a tese proposta no item 6 deste voto.

7.5) Recurso Especial 2059576, Tema 1241

Acompanho o Ministro Ribeiro Dantas em relação à solução para o caso concreto, mas divirjo para fixar a tese proposta no item 6 deste voto.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO**

Número Registro: 2021/0313183-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.963.433 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 15007957820198260126

PAUTA: 08/05/2025

JULGADO: 05/06/2025

RelatorExmo. Sr. Ministro **MESSOD AZULAY NETO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUÍS OPPERMAN THOMÉ

Secretária

Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA : MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
INTERES. : GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR PÚBLICO
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA PÚBLICA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

SUSTENTAÇÃO ORAL

O Dr. Rafael Muneratti (Defensor Público do Estado de São Paulo) sustentou oralmente
pela parte Recorrente: Arthur Walvike de Assis Silva.

O Dr. Paulo Roberto da Silva Marquezini (Defensor Público do Estado de Mato Grosso)
sustentou oralmente pela parte Interessada: GAETS - Grupo De Atuação Estratégica das
Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores.

O Dr. Victor Minervino Quintiere sustentou oralmente pela parte Interessada: ANACRIM -
Associação Nacional da Advocacia Criminal.

O Dr. Robson de Souza (Subdefensor Público-Geral Federal) sustentou oralmente pela
parte Interessada: Defensoria Pública da União.

O Dr. Ivan Francisco Pereira Agostinho (Subprocurador-Geral de Justiça Criminal do
Ministério Público do Estado de São Paulo) sustentou oralmente pela parte Recorrida:
Ministério Público do Estado de São Paulo.

C542164494165618615@ 2021/0313183-7 - REsp 1963433
CERTIDÃO

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO**

Número Registro: 2021/0313183-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.963.433 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após as sustentações orais e o voto do Sr. Ministro Relator, negando provimento ao recurso especial e fixando teses, pediu vista antecipada (coletiva) o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Aguardam os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54216449416561818615@ 2021/0313183-7 - REsp 1963433

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO**

Número Registro: 2021/0313183-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.963.433 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 15007957820198260126

PAUTA: 08/05/2025

JULGADO: 05/02/2026

RelatorExmo. Sr. Ministro **MESSOD AZULAY NETO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretária

Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA : MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
INTERES. : GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR PÚBLICO
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA PÚBLICA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Retomado o julgamento, após a disponibilização de voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Terceira Seção, por unanimidade, deferiu o pedido de vista do Sr. Ministro Messod Azulay Neto nos Temas Repetitivos n. 1.154 e 1.241.

Aguardam os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Não participaram do julgamento a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão, por não comporem a Seção à época das sustentações orais. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5421644941656181865@ 2021/0313183-7 - REsp 1963433

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO**

Número Registro: 2021/0313183-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.963.433 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 15007957820198260126

PAUTA: 08/05/2025

JULGADO: 11/02/2026

RelatorExmo. Sr. Ministro **MESSOD AZULAY NETO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO

Secretário

Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA : MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
INTERES. : GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR PÚBLICO
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA PÚBLICA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Seção, por unanimidade, deliberou pela renovação das sustentações orais nos Temas Repetitivos n. 1.241 e n. 1.154, com a inclusão dos recursos especiais repetitivos na pauta de julgamento do dia 05/03/2026, para intimação das partes.

Não participaram do julgamento a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5421644941656181865@ 2021/0313183-7 - REsp 1963433



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1963433 - SP (2021/0313183-7)

RELATOR : **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS
CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA
CRIMINAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
INTERES. : GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS
DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL
NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA
PÚBLICA
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE -
DEFENSOR PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR
PÚBLICO

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

I. Contextualização

A controvérsia afetada para discussão sob o rito dos recursos repetitivos no **Tema n. 1.241** tem a seguinte delimitação: **“Possibilidade de utilização da quantidade e variedade das drogas apreendidas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”**.

Inicialmente, levado o tema a julgamento pelo relator, Ministro **Ribeiro Dantas**, foi proposta a fixação da seguinte tese: **“a quantidade da droga, por si só, não pode afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, contudo, pode servir de parâmetro para modular a fração de diminuição da pena entre 1/6 e 2/3”**.

Na ocasião, pedi vista dos recursos afetados para examinar com mais vagar a questão em debate, oportunidade em que observei aos pares que a tese então proposta no voto de Sua Excelência avançava sobre a controvérsia objeto do **Tema n. 1.154**, de relatoria do Ministro **Messod Azulay Neto**, que consiste em definir se **“Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado”**.

Diante dessa constatação, ao devolver a vista já na sessão subsequente, propus a suspensão do julgamento do Tema n. 1.241 para aguardar a apresentação do voto do relator no Tema n. 1.154, a fim de que ambos fossem decididos em conjunto, em virtude da íntima relação entre eles.

Acatada a sugestão pelo colegiado, o Ministro **Messod Azulay Neto** levou o Tema n. 1.154 a julgamento, oportunidade em que, lido o voto do eminente relator, pedi vista coletiva de todos os feitos (do Tema n. 1.154 e do Tema n. 1.241), com o objetivo de analisar melhor as nuances na redação de cada uma das teses propostas.

II. Principais julgados da 3ª Seção sobre a matéria e propostas de teses em discussão

O eminente Ministro **Ribeiro Dantas** bem lembrou, em seu voto, dois importantes julgamentos sobre o tema no âmbito desta Terceira Seção. Inicialmente, em sessão realizada no dia **9/6/2021**, no julgamento do **REsp n. 1.887.511/SP**, de relatoria do Ministro **João Otávio de Noronha**, o colegiado havia fixado as seguintes diretrizes:

1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, **somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.**

3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base.

Já no ano de 2022, por ocasião do julgamento do **HC n. 725.534/SP**, relatado pelo Ministro **Ribeiro Dantas**, a **Terceira Seção** **reviu as orientações constantes nos itens 1 e 2** e passou a adotar o posicionamento segundo o qual **a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.**

No Tema n. 1.241, então, o Ministro relator propunha, inicialmente, a reafirmação desse entendimento, com a fixação da tese de que “a quantidade da droga, por si só, não pode afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, contudo, pode servir de parâmetro para modular a fração de diminuição da pena entre 1/6 e 2/3”, tese também sugerida pelo Ministério Público Federal.

Em versão atualizada de seu voto, todavia, alterou a tese proposta, de modo a tratar apenas sobre a modulação da fração do redutor: "A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de

diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria".

O **Ministério Público do Estado de Minas Gerais**, por sua vez, sugeriu o seguinte complemento:

- a) a natureza e a quantidade de drogas são circunstâncias que podem ser sopesadas na primeira ou na terceira fases da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, não havendo obrigatoriedade na utilização desses fatores em determinada fase, nos termos do julgamento do HC 725534/ SP, de relatoria do exmo. Min. Ribeiro Dantas, publicada em 01/06/22;
- b) consideradas a natureza e a quantidade de drogas na terceira fase da dosimetria da pena, tais circunstâncias configuram elementos idôneos suficientes para modulação da fração de redução da pena a ser aplicada pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e
- c) no processo de reestruturação da dosimetria, **é lícito ao julgador**, atento aos fins da pena e à correta e adequada individualização da sanção penal, em conformidade ao princípio da proporcionalidade e da vedação à proteção deficiente, **deslocar a valoração da natureza e da quantidade de drogas da primeira para terceira fase da dosimetria, considerando que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, a avaliação de tais circunstâncias na primeira fase pode acarretar redução drástica das penas, tornando-as diminutas, gerando, por evidente consequência, resposta estatal manifestamente insuficiente para crimes graves e envolvendo grande quantidade de entorpecente.**

O **Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (Gaets)**, a seu turno, propôs um **retorno ao entendimento firmado no REsp n. 1.887.511/SP**, para estabelecer que a natureza e a quantidade de drogas sejam consideradas **apenas e obrigatoriamente na primeira fase da dosimetria** e, para modular a fração de diminuição da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sejam usadas somente circunstâncias residuais do art. 59 do CP.

No mesmo sentido foram as manifestações da **Defensoria Pública da União** e da **Anacrim**.

Ao apresentar seu voto no **Tema n. 1.154**, o relator, Ministro **Messod Azulay Neto**, fez a seguinte proposta:

Adotando essas premissas teóricas, manifesto minha adesão às propostas trazidas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, com pequenas alterações e com acréscimo de um item, nos seguintes termos:

6.1) A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas sempre de forma conjunta. Não é possível, portanto, realizar a aplicação separada como se fossem elementos autônomos;

6.2) A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas preferencialmente na terceira fase da dosimetria da pena, para modular a fração de diminuição, salvo quando não incidir na hipótese a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, caso em que essa circunstância poderá ser aplicada na primeira etapa da dosimetria para aumentar a pena-base;

6.3) Caso a instância anterior tenha afastado a incidência da minorante e valorado a natureza e a quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, mas o tribunal, em recurso da defesa, decida aplicar o redutor, deverá, se possível, deslocar a aplicação dessa circunstância para a terceira fase, a fim de modular a fração de diminuição, o que não configura reformatio in pejus.

6.4) Não configura bis in idem considerar a quantidade e a natureza de drogas como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, como elemento fático indicador de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa para afastar a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Somente haverá bis in idem se essa circunstância for usada, simultaneamente, para aumentar a pena-base e para modular a fração de redução da pena na terceira fase.

6.5) A apreensão de elevada quantidade de drogas, o contexto de alto grau de profissionalismo, a sofisticada logística de transporte ou a complexa estrutura de armazenamento, conjunta ou separadamente consideradas, configuram fundamento idôneo para afastar a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicarem a dedicação do agente a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa.

Sobre esse tema, o **Ministério Público Federal** apresentou pareceres distintos em cada um dos recursos afetados. Nos REsp's n. 1.963.433/SP e 1.964.296/MG, o Subprocurador-Geral da República **Antônio Carlos Pessoa Lins** propôs “o reconhecimento da **impossibilidade** de se considerar a natureza e quantidade do entorpecente apreendido como elementos suficientes para, **por si sós**, ensejarem a conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e, assim, obstar, indevidamente, o reconhecimento da

minorante do tráfico privilegiado”. Já no REsp n. 1.963.489/MS, o Procurador Regional da República no exercício da função de Subprocurador-Geral da República **Cláudio Dutra Fontella** sugeriu a fixação do entendimento de que “a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser considerados como indicativos da dedicação a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06”.

O **Ministério Público do Estado de São Paulo** pleiteou que fosse “revisto o entendimento atual dessa Corte, de modo a se permitir que, por decisão motivada, se reconheça ser a apreensão de expressiva quantidade de droga ilícita óbice suficiente para o afastamento da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas”.

A **Anacrim** e o **Gaets**, por sua vez, defenderam a manutenção do entendimento de que, “isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da legalidade e do próprio sistema trifásico da dosimetria da pena”.

Feita essa breve contextualização, passo a tecer algumas considerações sobre as teses em debate.

III. Quantidade de drogas e incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação a esse ponto, é importante fazer algumas considerações sobre aspectos que, em meu entendimento, devem ser objeto de preocupação por todos nós julgadores.

O legislador, a meu ver, não foi feliz com a redação desse dispositivo previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e sua interpretação tem sido a mais equívoca, no sentido de diversas soluções, ou plurívoca, em sua interpretação por

diversos tribunais e por juízos de todas as instâncias, porque há situações concretas que parecem evidenciar uma consequência que a lei aparentemente não quis contemplar com essa minorante.

Não há como perder de vista haver situações que, pela quantidade de drogas apreendidas ou pela tamanha variedade de substâncias, dispensariam, a meu sentir, a necessidade de outros fatores para afastar o benefício, notadamente quando apreendidas em contexto de alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento, por indicar a dedicação habitual do agente a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa.

Deveras, há diversos julgados – tanto o Supremo Tribunal Federal quanto desta Corte Superior de Justiça – no sentido de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é **hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006**, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

Conforme entendimento que externei por ocasião do próprio julgamento do referido **REsp n. 1.887.511/SP**, a elevadíssima quantidade de drogas apreendidas, em contexto de alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento, pode, na minha compreensão, ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas, **porque nenhuma pessoa sozinha, salvo raríssimos casos de indivíduos bilionários, conseguiria adquirir tamanha quantidade de drogas. É preciso haver uma organização por trás dela, toda uma estrutura, de maneira que seria uma negação da realidade não afastarmos o benefício nessas situações.**

A título de exemplo, menciono: STJ, **AgRg no AREsp n. 359.220/MG**, Rel. Ministra **Maria Thereza de Assis Moura**, 6ª T., DJe 17/9/2013; **AgRg no HC n. 499.936/SP**, Rel. Ministro **Jorge Mussi**, 5ª T., DJe 1º/7/2019; **AgRg no HC**

596.077/SP, Rel. Ministro **Reynaldo Soares da Fonseca**, DJe 20/10/2020; **AgRg no AREsp 1.591.547/RO**, Rel. Ministro **Nefi Cordeiro**, 6ª T., DJe 19/8/2020.

Ainda: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que **a elevada quantidade de drogas apreendida**, tal como ocorreu na hipótese, **é circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas**” (**AgRg no REsp n. 1.870.949/PR**, Rel. Ministra **Laurita Vaz**, 6ª T., DJe 6/10/2020).

Também o **Supremo Tribunal Federal**, por ocasião do julgamento do **HC n. 111.666/MG**, de relatoria do Ministro **Luiz Fux** (1ª T., DJe 23/5/2012), consignou que “**a apreensão de grande quantidade de droga é fator que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas**”, circunstância “**obstativa da aplicação da referida minorante**”.

Diversos casos julgados cotidianamente nesta Corte retratam, a meu ver, situações que não se compatibilizam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas. Em verdade, **não se mostra razoável admitir que alguém preso com dezenas, centenas de quilos ou até toneladas de drogas** ostente a condição de pequeno traficante, de modo a ser merecedor do benefício em questão.

Firme na importância de se observarem os precedentes e de se adotar interpretação uniforme das leis – até para garantir uma ordem jurídica mais coerente, mais estável e com maior previsibilidade quanto à interpretação adotada pelo Poder Judiciário –, **tenho me curvado ao posicionamento firmado pela Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça**, para reconhecer a inidoneidade desse argumento para justificar a impossibilidade de incidência do redutor, qual seja, a quantidade de drogas apreendidas.

Todavia, diante desta oportunidade de reexame e da iminência de que a tese ora vigente assumira caráter obrigatório sob a sistemática dos recursos repetitivos, peço vênica para reavivar a discussão e trazer essas breves ponderações sobre o tema.

IV. *Bis in idem* na individualização da pena no crime de tráfico privilegiado

Faço lembrar que, por ocasião do julgamento do **HC n. 112.776/MS** – *leading case* sobre a discussão acerca de *bis in idem* em casos de dosimetria da pena no crime de tráfico de drogas –, em sessão plenária ocorrida no dia **19/12/2013**, o **Supremo Tribunal Federal**, por maioria de votos, **firmou o posicionamento de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas só podem ser usadas, na dosimetria da pena – na primeira ou na terceira fase –, sempre de forma não cumulativa**. Esse fato privilegia, de acordo com o relator, Ministro **Teori Zavascki**, o poder de discricionariedade concedido ao juiz na dosimetria, como também o princípio constitucional da individualização da pena. Para o relator, sopesar a natureza e a quantidade de drogas em duas fases do cálculo da pena caracteriza *bis in idem*.

Ficaram vencidos, em parte, os Ministros **Luiz Fux, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio**, que concediam a ordem em menor extensão. Para eles, a análise das circunstâncias da natureza e da quantidade de drogas, na primeira e na terceira fase da dosimetria, **não configuraria *bis in idem***, pois o que elevaria a pena-base seria a intensidade da lesão à saúde pública, enquanto **a causa de diminuição seria decorrente do grau de envolvimento do réu com a criminalidade organizada ou da sua maior devoção à atividade criminosas**.

É certo, no entanto, que, no referido julgado, a quantidade de drogas havia sido utilizada, na primeira fase, com vistas à exasperação da pena-base e, na terceira, para a **escolha da fração** de redução de pena relativa à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, **e não para a incidência ou não da causa especial de diminuição em comento**.

Vale dizer, não estava em discussão, naquele caso, se foram preenchidos ou não os requisitos da primariedade, dos bons antecedentes, da não dedicação a atividades delituosas e da não integração em organização criminosa, visto que o Juiz sentenciante já havia reconhecido o preenchimento, de forma cumulativa, de todos esses elementos pelo acusado.

No julgamento do **HC n. 109.193/MG** (Rel. Ministro **Teori Zavascki**), também ocorrido na mesma sessão do dia **19/12/2013**, foi novamente discutida a possibilidade de utilização, na terceira fase da dosimetria, da natureza da droga apreendida **para a fixação do *quantum* de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.**

A Suprema Corte denegou a ordem, por concluir que, naquele caso específico, teria havido a consideração da natureza da substância entorpecente apreendida **somente** na terceira etapa da dosimetria, **ou seja, para a escolha do *quantum* de diminuição de pena pela minorante em questão**, sem haver, portanto, violação do princípio do *ne bis in idem*.

Igualmente, no julgamento da **Repercussão Geral no ARE n. 666.334/AM (Tema n. 712)**, de relatoria do Ministro **Gilmar Mendes**, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, considerou que as circunstâncias da **natureza e da quantidade** de drogas apreendidas (naquele caso, 162,57 g de cocaína) devem ser levadas em consideração em **somente uma das fases do cálculo da pena**, em observância à vedação do *bis in idem*.

No entanto, ressalto que o julgado mencionado também dizia respeito a caso em que se consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida na primeira etapa da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis e, **na terceira fase, para justificar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 no patamar de 1/3**, e não na fração máxima de 2/3.

Não desconheço, por certo, que **há uma tendência dos órgãos fracionários do STF** em considerar *bis in idem* também os casos de utilização da quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, e, na terceira, **para justificar a impossibilidade de incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006** (seja a título de dedicação do agente a atividades criminosas, seja por integração em organização criminosa).

Todavia, essa interpretação não parece decorrer da *ratio* da decisão do plenário da Corte no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 712, mas

sim de uma replicação simplista da tese firmada, cuja enxuta redação final acabou não contemplando adequadamente todas as nuances da decisão e deu margem a essa leitura mais abrangente (“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”).

É imperioso salientar, portanto, que, a rigor, **o Plenário** do Supremo Tribunal Federal **nunca decidiu** que configura *bis in idem* a utilização da quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, e, na terceira, **para justificar a impossibilidade de incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006** (seja a título de dedicação do agente a atividades criminosas, seja por integração em organização criminosa).

Particularmente, considero que **não configura bis in idem** a utilização da **quantidade de drogas apreendidas na primeira fase**, para fins de exasperação da pena-base (conforme determina o próprio art. 42 da Lei n. 11.343/2006), e, **novamente, na terceira, para impedir a aplicação do redutor** previsto no § 4º do art. 33 da referida lei.

Isso porque a consideração da natureza e da quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, para fins de aumento da pena-base, justifica-se em razão da **intensidade da lesão à saúde pública**, bem jurídico penalmente tutelado nos crimes de tráfico de drogas e afins; já na terceira etapa, esses elementos são utilizados como **dados fáticos** para a **aferição do envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de dedicação a atividades delituosas**, isto é, o **preenchimento de requisitos para a concessão de um benefício legal**, **o que é bastante diferente de promover dois aumentos na pena com base no mesmo fundamento fático.**

Dito de outro modo, entendo que se estaria tratando da utilização de determinado parâmetro de referência para **momentos e finalidades distintas**, justamente para se alcançar a **justa e correta** reprimenda necessária para a reprovação e a prevenção do delito, à luz das circunstâncias em que cometido.

Ademais, veja-se que **a própria legislação reconhece, expressamente**, a possibilidade de sopesar os **maus antecedentes** na **primeira fase** da dosimetria, para fins de exasperação de pena-base, e, **novamente, na terceira, para impedir a incidência do redutor em questão**, sem que a jurisprudência – tanto desta Corte Superior de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal – **haja cogitado reconhecer a ocorrência de *bis in idem* em tal situação**.

O mesmo ocorre com a **reincidência**, que é tranquilamente valorada **tanto na segunda etapa** de cálculo da reprimenda, como agravante genérica (art. 61, I, do Código Penal), **quanto na terceira**, para também impedir a aplicação da minorante.

Da mesma forma, esta Corte, ao estabelecer que a condenação pelo crime de **associação para o tráfico de drogas** (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, **nunca cogitou reconhecer a existência de *bis in idem* pela dupla valoração da condenação pelo art. 35 contra o réu** (para impor a pena desse crime e para afastar a minorante do art. 33, § 4º). **Igualmente, quando o réu é preso com diversas armas de fogo, além de condenado pela majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas (ou pelo crime autônomo de posse ou porte de arma de fogo), também lhe é negada a minorante do art. 33, § 4º**, ao argumento de que tais circunstâncias indicam a dedicação a atividades criminosas.

Por que, então, empregar raciocínio diverso, com soluções jurídicas distintas, quando o parâmetro a ser utilizado na dosimetria da pena é a quantidade de drogas apreendidas? A meu ver, essa jurisprudência que se consolidou, com todas as vênias, está **dissociada** do que o Código Penal prevê.

Veja-se, ainda, uma **situação análoga** que pode ocorrer no crime de furto privilegiado (Art. 155, § 2º, do CP: “**Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada**, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”).

Imagine-se que um indivíduo primário subtraia para si, por meio de alguma fraude, todas as reservas financeiras de uma família, no total de 100 milhões de reais. Seria natural – e plenamente compatível com a jurisprudência desta Corte –, nesse caso, **aumentar a pena-base** em virtude do vulto da subtração

– o que poderia ser enquadrado no art. 59 do CP como culpabilidade, circunstâncias ou consequências do crime, por exemplo – e, **além disso, afastar a aplicação do art. 155, § 2º**, sob o argumento de que não é de “pequeno valor” a coisa furtada.

Todavia, a prevalecer a lógica da interpretação reinante no crime de tráfico de drogas, **o julgador seria obrigado a conceder o privilégio do furto de pequeno valor a quem subtraiu 100 milhões de reais, só pelo fato de que a pena-base foi aumentada em virtude do montante expressivo da subtração**. Ou então, também de forma incompatível com a imensa gravidade concreta do delito, seria necessário desconsiderar por completo o valor monumental da subtração no momento de fixar a pena-base só para poder afastar o benefício do § 2º (furto privilegiado).

Outro argumento que invoco em abono à minha compreensão diz respeito ao fato de que, na prática, o acolhimento da tese de que há *bis in idem* na utilização da quantidade de drogas, para fins de exasperação da pena-base, e, na terceira fase da dosimetria, para justificar o afastamento da minorante, pode acabar levando a situações muitas vezes **absurdas e desproporcionais do ponto de vista da correta individualização da pena e da justa reprimenda penal**.

Explico com o seguinte exemplo:

Suponha que um agente seja flagrado na posse de **1 tonelada de cocaína**. O Juiz sentenciante fixa a pena-base em 7 anos de reclusão, justificando o aumento da reprimenda na natureza e na elevada quantidade de drogas apreendidas, à luz, aliás, do que determina o próprio art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Caso adotada a tese do *bis in idem*, esses mesmos elementos (natureza e quantidade de drogas) não poderiam ser novamente valorados na terceira fase da dosimetria, para demonstrar que o agente não seria um pequeno traficante ou um traficante eventual e, conseqüentemente, justificar o afastamento da minorante. À ausência de outros elementos específicos dos autos, não restaria ao Magistrado, portanto, outra alternativa senão a de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena.

Ademais, se as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas não podem ser valoradas para fins de exasperação da pena-base e, novamente, para a escolha da fração do redutor, **o Juiz também estaria adstrito a aplicar a minorante no patamar máximo de 2/3, o que conduziria a uma reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão** (abstraindo-se, obviamente, a existência de eventuais agravantes ou atenuantes ou de quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição).

Diante de tal situação hipotética (mas cuja matéria é muito recorrente no dia a dia deste Tribunal), indago: **seria razoável, proporcional e consentâneo com o princípio constitucional da individualização da pena** punir com uma reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão um agente flagrado na posse de **1 tonelada** de cocaína? Ainda: é razoável admitir que alguém preso em flagrante com **1 tonelada** de cocaína ostente a condição de traficante eventual ou de pequeno traficante, de modo a ser merecedor da referida minorante?

Com a máxima vênia às posições em contrário, **penso que a jurisprudência que se tem construído** – tanto no STF quanto nesta Corte – acaba, na prática, **esvaziando, sobremaneira**, esse dispositivo legal, no que diz respeito ao sentido que, a meu sentir, deveria dele se extrair.

É de rigor consignar que uma interpretação teleológica do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 à luz da política criminal de drogas instituída pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad permite inferir que o espírito da norma contida no referido dispositivo de lei é o de **conferir tratamento mais brando ao pequeno e eventual agente do tráfico e não ao que exerce, com habitualidade ou profissionalismo, atividade criminosa, ou ao que colabora, de modo relevante, para a disseminação da droga, ciente de que faz parte de uma organização criminosa**.

A jurisprudência que hoje se tem, no entanto, é a seguinte: é necessário o trânsito em julgado da condenação para reconhecer maus antecedentes; processos em andamento não podem ser considerados para concluir que o réu se dedica a atividades criminosas e, assim, afastar o redutor; a quantidade de drogas apreendidas, ainda que seja elevada, também não pode ser sopesada para, isoladamente, levar à conclusão de que o acusado é dedicado a atividades

criminosas; ainda que seja uma tonelada de cocaína, não se pode considerar isso para afastar a incidência da minorante em questão. Diante disso, indago: **o que restaria, então, para justificar o afastamento dessa causa de diminuição de pena?**

Não há dúvidas de que devemos sempre ter uma flexibilidade de interpretação diante da realidade do sistema penitenciário brasileiro, que é de notória precariedade. No entanto, não podemos utilizar essa justificativa para obviar a literalidade da lei ou a própria teleologia da lei. E a Lei n. 11.343/2006 criou um **benefício excepcional**, sendo certo que aquele que comete crime previsto no *caput* e no § 1º do art. 33 da Lei de Drogas responde por uma pena mínima de 5 anos de reclusão. Apenas em hipóteses excepcionais, quando não evidenciada sua participação em organização criminosa ou em atividades criminosas, e for o agente primário e possuidor de bons antecedentes, é que poderá ser beneficiado com a redução de pena.

V. Consideração da natureza e da quantidade de drogas na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena

Feitas essas considerações, retorno ao cerne da controvérsia em discussão no julgamento do Tema n. 1.241: a possibilidade ou não de valorar a natureza e a quantidade de drogas para o fim de modular a fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

As Defensorias Públicas se escoram substancialmente no argumento de que, em decorrência do art. 42 da Lei de Drogas e do princípio da especialidade, essas circunstâncias deveriam ser consideradas **sempre e apenas na primeira fase da dosimetria da pena**. Com base na pesquisa empírica de mestrado do Defensor Público Thiago Yukio, do Estado de Santa Catarina, sustentam, ainda, que:

A valoração na primeira fase é, em geral, mais benéfica ao acusado por duas razões:

(a) o impacto quantitativo na pena é geralmente menor. Por regra, na primeira fase o aumento não supera 10 meses de pena (1/6 sobre a pena mínima) e, ao final, a redução é aplicada na fração máxima de 2/3 sobre o total da pena até então alcançada (e não sobre a pena mínima). Isso significa que, aplicada a fração de 2/3,

no mínimo haverá uma redução de 3 anos e 4 meses de pena; já nos casos em que a pena-base é estabelecida no mínimo legal, a fração redutora pode variar até a redução mínima de 1/6 (o que pode representar uma diminuição de apenas 10 meses de pena);

(b) além disso, o aumento da pena na primeira fase pode ser neutralizado por eventuais circunstâncias atenuantes (na prática forense é muito comum a incidência das atenuantes da confissão e da chamada “menoridade relativa”), ao passo que, se não houver aumento da pena-base, elas são simplesmente desprezadas em virtude da orientação sedimentada no polêmico Verbete n. 231 do STJ.”

(CAMPOS, Thiago Yukio Guenka. *Racionalidade da motivação na determinação judicial da pena: uma análise de decisões prolatadas em 2018 pelo Superior Tribunal de Justiça*, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, 2019, 241f., p. 205-206)

Já as propostas do **MPF e do MPMG**, a seu turno, entendem possível o uso dessas circunstâncias na terceira fase da dosimetria, desde que não hajam sido usadas na primeira etapa.

Com a devida vênia a ambas as posições, **o fato de que a primeira seja geralmente mais benéfica ao réu e a segunda mais benéfica à acusação não significa que uma ou outra seja correta ou errada**, o que deve ser medido pelo amparo de cada uma das teses no ordenamento jurídico, e não somente pelas consequências práticas que acarretam.

A proposta das defensorias, contudo, tem um fundamento que não pode ser desconsiderado: deixar ao julgador a plena possibilidade de escolher em que etapa da dosimetria irá valorar a natureza e a quantidade de drogas realmente abre margem para o tratamento distinto de pessoas em idêntica situação, em grave afronta à isonomia.

Por isso, é **necessário estabelecer**, a partir da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, **em qual fase do processo dosimétrico essa circunstância deve ser valorada**, de modo a afastar do julgador a possibilidade de escolha, cuja discricionariedade, de tão ampla, levaria – como de fato tem levado, segundo demonstrou empiricamente a pesquisa de Thiago Yukio – à arbitrariedade.

Compreendo, todavia, que essa valoração **não deve ocorrer sempre na primeira fase – como propõem as defensorias –, mas sim na terceira**, salvo, naturalmente, quando não estiver presente a minorante do art. 33, § 4º, ocasião em que o julgador poderá valorar a natureza e a quantidade de drogas na primeira fase. Explico.

É bem verdade que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 parece sugerir que a natureza e a quantidade de drogas devam ser consideradas na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP. A leitura do dispositivo, entretanto, deve ser feita à luz do princípio da especialidade, o qual, ao contrário do sugerido pelas defensorias, não aponta para a aplicação preferencial na primeira fase, mas sim na terceira.

Isso ocorre, aliás, com toda e qualquer circunstância que está prevista, ao mesmo tempo, no art. 59 do CP e como causa de aumento, qualificadora ou agravante.

O motivo do crime, por exemplo, embora esteja previsto no art. 59 do CP, deverá ser valorado como qualificadora no homicídio quando for fútil ou torpe. Não cabe ao julgador, nesse caso, optar por considerar o motivo como circunstância negativa da primeira fase, em lugar de qualificadora.

Da mesma forma, se um **roubo é praticado com arma de fogo** (causa de aumento de pena), ainda que isso também possa se enquadrar como circunstância judicial negativa do art. 59 (culpabilidade negativa, por exemplo), **não pode o magistrado escolher aumentar a pena-base com fundamento nessa circunstância e deixar de aplicar a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, do CP.**

Ou, ainda, se um **estelionato é cometido contra pessoa idosa**, isso **não pode ser valorado, por exemplo, na culpabilidade do agente na primeira fase, porque a circunstância está prevista como causa de aumento na terceira (art. 171, § 4º, do CP).** Se o crime não consistir em estelionato, o aumento deverá ocorrer na segunda fase, não na primeira, porque incidirá a agravante genérica do art. 61, II, "h" , do CP (praticado contra maior de 60 anos).

A especialidade incide, portanto, sempre da terceira em direção à primeira fase da dosimetria, e não no sentido oposto. Justamente por isso, penso que a natureza e a quantidade de drogas devam ser valoradas na terceira fase da dosimetria sempre que estiver presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Não ignoro, naturalmente, que, diferentemente dos demais exemplos acima mencionados, a natureza e a quantidade de drogas não estão previstas expressamente no § 4º como fatores de modulação da fração redutora. É preciso considerar, entretanto, que **a lei não estabeleceu os critérios de aplicação da minorante entre 1/6 e 2/3, de modo que cabe ao intérprete extrair do ordenamento jurídico os meios adequados para tanto.**

Nesse ponto, é pertinente a análise de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

A grande questão é sobre o quantum a diminuir, dentro do parâmetro fixado pelo legislador (1/6 a 2/3). Como já dissemos, para obter a causa de diminuição de pena, os requisitos devem estar todos preenchidos cumulativamente. **Ou se preenchem todos os requisitos ou não se preenche nenhum. Ou o sujeito é primário ou não é, ou tem bons antecedentes ou não tem, ou participa de atividades criminosas ou não participa, ou integra organização criminosa ou não integra. Não há meio-termo. Assim, como não é possível fazermos gradações utilizando os parâmetros indicados pelo próprio legislador (primariedade, bons antecedentes, não participar de atividades criminosas e não integrar organização criminosa), pois tais conceitos não admitem meio-termo, entendemos que o intérprete deve se valer de outros elementos do caso concreto para avaliar o quantum da causa de diminuição. Do contrário, sempre que tivesse direito ao benefício, a causa de diminuição seria inexoravelmente aplicada no máximo (2/3). Assim, entendemos que o magistrado deverá analisar o quanto diminuir à luz dos elementos do art. 42, notadamente a natureza e a quantidade da droga.**

(Lei de drogas: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. São Paulo: Método, 2008. p. 126-127)

Com efeito, uma vez que os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não admitem gradação, a consideração da natureza e da quantidade de drogas desponta como o principal e mais adequado critério para a dosagem da minorante, sob pena de fazê-la incidir sempre em grau máximo, como bem

demonstra a praxe forense nos casos em que essa circunstância já foi valorada na primeira fase.

A tese proposta pelas Defensorias Públicas, de considerar apenas as circunstâncias residuais do art. 59 do CP, não resolve o problema. Primeiro, porque são circunstâncias também previstas para a primeira fase da dosimetria, de modo que, pela lógica da argumentação das defesas, também deveriam ficar restritas a essa etapa, assim como as do art. 42 da Lei de Drogas. Segundo, porque são circunstâncias pouco adequadas às especificidades do crime de tráfico de drogas e que dificilmente se aplicam a esse delito.

Afinal, o motivo (lucro fácil) e as consequências (danos à saúde pública) são inerentes ao tipo penal de tráfico, crime que também não tem vítima certa; os antecedentes já afastam a incidência da minorante; a conduta social e a personalidade são de difícil aferição; por fim, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, no crime de tráfico, em geral acabam sendo extraídas, justamente, da quantidade e da natureza das drogas apreendidas no caso concreto.

Assim, **proponho que a natureza e a quantidade de drogas sejam valoradas sempre na terceira fase da dosimetria da pena, salvo quando não incidir na hipótese a minorante** prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, oportunidade em que essa circunstância poderá ser aplicada na primeira etapa para aumentar a pena-base.

Por consequência, caso a instância anterior haja afastado a incidência da minorante e valorado a natureza e a quantidade de drogas na primeira fase, mas o tribunal, em recurso da defesa, decida aplicar o redutor, deverá, se possível, deslocar a aplicação dessas circunstâncias para a terceira fase, a fim de modular a fração de diminuição. Tal conduta, na linha do estabelecido por essa corte no Tema Repetitivo n. 1214, não configura *reformatio in pejus*: “É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, **não implicam *reformatio in pejus* a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial**, nem o simples reforço de

fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”.

Lembro também, em sentido análogo, o consolidado entendimento desta Corte de que não configura *reformatio in pejus* corrigir a classificação e deslocar a valoração de uma condenação criminal transitada em julgado da segunda fase (como reincidência) para a primeira (como mau antecedente).

Mas esse deslocamento deve ocorrer **não por ser mais prejudicial ao acusado, na linha sugerida pelo Ministério Público de Minas Gerais, mas sim por haver na sistemática de aplicação da pena do ordenamento jurídico brasileiro um sentido preferencial de aplicação das circunstâncias judiciais**, da terceira em direção à primeira fase da dosimetria.

VI. Teses sugeridas

Feitas essas considerações, passo a **sintetizar** as teses cuja fixação proponho neste julgamento.

Inicialmente, **endosso** a tese contida no **item 6.1** acrescentado no voto do Ministro **Messod Azulay Neto**, no qual propõe que “A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas sempre de forma conjunta. Não é possível, portanto, realizar a aplicação separada como se fossem elementos autônomos”.

Trata-se de mero reforço ao quanto já decidido por esta Terceira Seção no **Tema Repetitivo n. 1262**, no segundo semestre de 2025, em que se estabeleceu a tese de que: “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza”

É, também, mera reafirmação do entendimento dominante no STF e neste Superior Tribunal de que “**A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa**

circunstância especial” (REsp n. 1.976.266/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 03/11/2022).

No mesmo sentido, menciono: **AgRg no AREsp n. 2.755.915/SC**, Rel. Ministro **Ribeiro Dantas**, 5ª T., DJe 17/12/2024); **HC n. 864.670/AM**, Rel. Ministro **Rogério Schietti**, 6ª T., DJe 2/4/2024; **HC n. 567.261/RJ**, Rel. Ministro **Nefi Cordeiro**, 6ª T., DJe 16/6/2020; **AgRg no RHC n. 169.343**, Rel. Ministra **Rosa Weber**, 1ª T., DJe 25/6/2021; **HC n. 146.391/SP**, Rel. Ministro **Celso de Mello**, decisão monocrática, DJe 15/2/2018; **HC n. 141.350/PR**, Rel. Ministro **Celso de Mello**, decisão monocrática, DJe 14/2/2018; **HC n. 156.794/SC**, Rel. Ministro **Edson Fachin**, decisão monocrática, DJe 18/12/2018.

No mais, proponho que:

2. A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas preferencialmente na terceira fase da dosimetria da pena, para modular a fração de diminuição da pena, salvo quando não incidir na hipótese a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, oportunidade em que essa circunstância poderá ser aplicada na primeira etapa para aumentar a pena-base.

3. Caso a instância anterior haja afastado a incidência da minorante e valorado a natureza e a quantidade de drogas na primeira fase, mas o tribunal, em recurso da defesa, decida aplicar o redutor, deverá, se possível, **deslocar a aplicação dessas circunstâncias para a terceira fase**, a fim de modular a fração de diminuição, o que não configura *reformatio in pejus*.

4. Não configura *bis in idem* considerar a quantidade e a natureza de drogas como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, como **elemento fático indicador de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006**. Só haverá *bis in idem* se essa circunstância for usada, simultaneamente, para aumentar a pena-base e para modular a fração de redução da pena na terceira fase.

5. A apreensão de elevadíssima quantidade de drogas, em contexto de alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa

estrutura de armazenamento, configura **fundamento idôneo para afastar a minorante** prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicar a dedicação do agente a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa.

VII. Distinções em relação às teses propostas pelo Ministro Messod Azulay Neto

Embora muito me honre a constatação de que o Ministro Messod Azulay Neto encampou, quase na íntegra, as teses por mim sugeridas na primeira versão do voto-vista que apresentei internamente aos pares no Tema n. 1.241, noto a existência de **algumas diferenças pontuais entre as nossas propostas**, no que concerne à redação do **item 6.5** do voto do relator, tese central do Tema n. 1.154.

Sua Excelência propõe que: “A apreensão de **elevada** quantidade de drogas, o contexto de alto grau de profissionalismo, a sofisticada logística de transporte ou a complexa estrutura de armazenamento, **conjunta ou separadamente consideradas**, configuram fundamento idôneo para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicarem a dedicação do agente a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa”.

Já no meu voto, a redação sugerida foi: “A apreensão de **elevadíssima** quantidade de drogas, **em contexto de** alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento, configura fundamento idôneo para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicar a dedicação do agente a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa”.

Há **duas distinções principais** no texto, que, apesar de singelas, implicam relevante alteração do sentido do enunciado.

Em **primeiro lugar**, adotei o adjetivo “**elevadíssima**”, ao passo que o Ministro Messod Azulay Neto preferiu a palavra “**elevada**”. De minha parte, a escolha do superlativo absoluto sintético foi proposital e tem uma razão clara de ser: reservar a possibilidade de afastamento da minorante a apreensões de quantidades verdadeiramente exorbitantes de entorpecentes, como aquelas em que

se apreendem toneladas ou centenas de quilos de drogas, nas quais a concessão da benesse legal se mostra claramente desproporcional.

Segundo penso, o adjetivo “elevada”, embora já aponte para montantes maiores do que o usual, não traduz suficientemente a extraordinariedade ora pretendida e, a meu ver, pode dar margem a que apreensões menores, mas ainda assim relevantes, também sejam indevidamente enquadradas na mesma categoria excepcional ora proposta.

Em **segundo lugar**, se mantida a expressão “**conjunta ou separadamente consideradas**” proposta pelo Ministro Messod Azulay Neto, bastará a menção à quantidade de drogas, independentemente do contexto da apreensão, para justificar o afastamento da minorante.

Já na redação por mim sugerida, a elevadíssima (não apenas elevada) quantidade de drogas deve ser **vinculada ao contexto da apreensão**, a fim de garantir que o afastamento da minorante seja reservado a cenários de “**alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento**”, dos quais se possa inferir a dedicação do agente a atividades criminosas.

Com a máxima vênia, da forma como redigida a tese proposta pelo Ministro Messod Azulay Neto e na falta de algum parâmetro mínimo para estabelecer o que é “elevada quantidade de drogas”, temo pela **insegurança jurídica** que o enunciado causará e pelo potencial gerador de recursos e impetrações que chegarão a este Superior Tribunal para definirmos se a quantidade de drogas era ou não elevada.

Ora, se, mesmo sob a égide do entendimento atual – em vigor desde 2021 –, boa parte dos juízes de primeiro grau e tribunais de origem ainda descumprem cotidianamente a diretriz da Terceira Seção e insistem em afastar a minorante com base apenas na natureza e na quantidade de drogas apreendidas (basta ver a infinidade de HCs e recursos que cada um de nós diariamente concede sobre esse tema até hoje), imaginem, eminentes pares, se lhes dermos carta branca para negar esse benefício com simples menção à “elevada quantidade de drogas”, sem nenhum parâmetro sobre o que isso significa? Afinal, o que seria “elevada quantidade de

drogas”? 50 g? 100 g? 200 g? 500 g? 1 kg? 2 kg? 10 kg? 50 kg? 100 kg? 1 tonelada?

Os próprios casos concretos submetidos a julgamento em cada um dos três recursos especiais afetados ao Tema n. 1.154 confirmam esse receio. No REsp n. 1.963.433/SP, houve apreensão de cerca de **250 g de crack**; no REsp n. 1.964.296/MG, cerca de **1,9 kg de crack**; no REsp 1.963.489/MS, **99 kg de maconha**. Segundo a compreensão do relator, em todos eles a quantidade de drogas, apesar de bastante díspar em cada caso, deve ser considerada elevada a ponto de justificar, por si só, o afastamento da minorante.

No primeiro caso, tratou-se de abordagem pontual do paciente em via pública, com extensão da diligência até o hotel em que ele estava hospedado, onde foram encontrados 250 g de crack; a minorante foi afastada pelas instâncias ordinárias com base apenas na quantidade de drogas e a pena imposta foi de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Se aplicado o redutor, por exemplo, na fração de 1/4 pela natureza e quantidade das drogas (o que era possível, porque a pena-base foi fixada no mínimo), a pena ficaria em 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

No segundo, apreendeu-se 1,9 kg de crack em veículo estacionado na rua depois de denúncia anônima recebida pela polícia; a minorante **foi aplicada** pelas instâncias ordinárias na fração de 1/6 e a pena ficou em **4 anos e 7 meses de reclusão, mais multa, em regime inicial semiaberto**.

No terceiro, 99 kg de maconha foram apreendidos durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Ponta Porã/MS, no porta-malas de veículo sem vestígios de adulteração e registrado em nome do próprio condutor, o qual recebeu R\$ 3.000,00 para transportar as drogas até o Estado de Minas Gerais. Quebrado o sigilo de dados do celular do réu, constatou-se, segundo o acórdão, a existência de conversa em que há referência “sobre outra situação em que o réu funcionaria como ‘batedor’ para o tráfico, a denotar nítida dedicação a atividades criminosas e participação em organização criminosa” (fl. 342 daqueles autos).

Em relação aos dois primeiros casos, embora 250 g e 1,9 kg de crack sejam quantidades relevantes dessa droga, não são exorbitantes a ponto de permitir que se presuma a dedicação habitual a atividades criminosas, tampouco integração a organização criminosa, sobretudo porque a apreensão não ocorreu em contexto de alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento e as instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento adicional que pudesse demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Ademais, os casos demonstram que a aplicação da minorante não significa, necessariamente, pena ínfima e desproporcional. Em ambos a pena superaria 4 anos de reclusão e não seria cabível regime aberto nem substituição por restritivas de direitos.

Já no caso em que houve apreensão de 99 kg de maconha, além da referência à expressiva quantidade de drogas, a investigação foi aprofundada com quebra de sigilo de dados depois da apreensão e o Tribunal de origem apontou a existência de conversa por aplicativo de mensagens no celular do réu que demonstrava a dedicação habitual dele à traficância, de modo que foi idôneo o afastamento do benefício.

Não bastasse a insegurança jurídica sobre o que significa “elevada quantidade de drogas”, penso que a redação da tese proposta por Sua Excelência ainda pode representar certo retrocesso no que concerne ao **rebaixamento do *standard* probatório** no crime de tráfico de drogas e ao agravamento do problema do **encarceramento em massa** no Brasil, na linha do que bem expuseram os representantes das defensorias públicas e da Anacrim em suas sustentações orais e memoriais.

Com efeito, embora eu comungue de boa parte das inquietações do relator quanto ao problema do tráfico de drogas no país, minha proposta tinha por objetivo apenas servir como mero **freio de arrumação** para corrigir distorções pontuais em casos de evidente desproporcionalidade que vez ou outra chegam a esta Corte, mas **sem abrir ampla margem para que qualquer indivíduo primário e de bons antecedentes que seja encontrado com alguma quantidade um pouco mais significativa de drogas seja privado do benefício do art. 33, § 4º**.

Faço lembrar, nesse ponto, que quantidades mais relevantes de droga podem ser perfeitamente conciliadas com a concessão da minorante, sem que isso implique, necessariamente, pena ínfima e desproporcional; basta considerar tal fator na modulação da fração de diminuição, até porque, **nos casos de transporte interestadual, já haverá incidência da majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006**, o que necessariamente acarretará **aumento de 1/6 a 2/3**. O que me parece indevido, isso sim, é beneficiar com o redutor quem foi apreendido com “**elevadíssima** quantidade de drogas, **em contexto de** alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento”.

Assim, as teses que ora proponho, conquanto representem maior rigor do que se vinha adotando neste Superior Tribunal em relação à aplicação do benefício contido no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não têm por objetivo ir na contramão dos avanços civilizatórios promovidos pelos tribunais superiores na compatibilização das previsões da Lei de Drogas com o devido processo legal e constitucional, como, por exemplo, o reconhecimento da possibilidade de liberdade provisória, de substituição da pena por restritivas de direitos e de fixação de regime inicial diferente do fechado.

Trata-se, apenas, em meu sentir, somente de corrigir uma distorção prática que o entendimento anterior acarretava, sem, todavia, colocar em risco o legado civilizatório acima descrito.

A fim de facilitar a visualização comparativa de cada uma das propostas, elaborei a seguinte tabela:

	Min. Ribeiro Dantas	Min. Messod Azulay Neto	Min. Rogerio Schietti Cruz
Valoração de Natureza e Quantidade de Drogas	<i>Não constou nas teses propostas</i>	Devem ser valoradas sempre de forma conjunta , nunca como elementos autônomos.	Devem ser valoradas sempre de forma conjunta , nunca como elementos autônomos.
Momento Preferencial de Valoração	<i>Não constou nas teses propostas</i>	Preferencialmente na terceira fase (modular fração). Só usar na 1ª fase se a minorante <i>não</i> for aplicada.	Preferencialmente na terceira fase (modular fração). Só usa na 1ª fase se a minorante <i>não</i> for aplicada.
Deslocamento de Fase (Recurso da Defesa)	<i>Não constou nas teses propostas</i>	Permitido. Se o tribunal aplicar o redutor em recurso, deve deslocar a valoração da 1ª para a 3ª fase. Não configura <i>reformatio in pejus</i> .	Permitido. Se o tribunal aplicar o redutor em recurso, deve deslocar a valoração da 1ª para a 3ª fase. Não configura <i>reformatio in pejus</i> .
Bis in idem (Pena-base e Fração da Minorante)	Veda a utilização simultânea da natureza/quantidade de drogas na 1ª fase e na modulação da fração (3ª fase).	Há bis in idem se usar simultaneamente natureza/quantidade de drogas para aumentar a pena-base e para modular (reduzir menos) a fração na 3ª fase.	Há bis in idem se usar simultaneamente natureza/quantidade de drogas para aumentar a pena-base e para modular (reduzir menos) a fração na 3ª fase.
Bis in idem (Pena-base e Afastamento da Minorante)	<i>Não constou nas teses propostas</i>	Não há bis in idem. Pode usar natureza/quantidade de drogas para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, como um indicio de dedicação a atividades criminosas para afastar a minorante.	Não há bis in idem. Pode usar natureza/quantidade de drogas para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, como um indicio de dedicação a atividades criminosas para afastar a minorante.

VIII. Casos concretos

Conforme antecipei ao longo do voto, em relação ao Tema n. 1.241, estou de acordo com a solução proposta pelo Ministro Ribeiro Dantas para o **REsp n. 2.059.576/MG** e o **REsp n. 2.059.577/MG**.

Já em relação ao Tema n. 1.154, de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, estou de acordo com o afastamento da minorante apenas no **REsp n. 1.963.489/MS**, uma vez que o Tribunal de origem apontou a existência de conversa por aplicativo de mensagens no celular do réu que demonstrava a dedicação habitual dele à traficância, de modo que foi idôneo o afastamento do benefício. No **REsp n. 1.963.433/SP**, em que houve apreensão de cerca de 250 g de crack, voto pela aplicação da minorante na fração de 1/4; no **REsp n. 1.964.296/MG**, em que a apreensão foi de cerca de 1,9 kg de crack, voto pela manutenção da fração de 1/6 aplicada pelas instâncias ordinárias.

IX. Dispositivo

À vista do exposto, em relação aos REsp's vinculados ao Tema n. 1.241, **acompanho o Ministro Ribeiro Dantas quanto à solução do caso concreto, mas diverjo parcialmente quanto às teses a serem fixadas**, nos termos propostos na fundamentação deste voto. Em relação aos REsp's vinculados ao Tema n. 1.154, **divirjo parcialmente** do Ministro Messod Azulay Neto quanto as teses fixadas e à solução dos casos concretos no **REsp n. 1.963.433/SP** e no **REsp n. 1.964.296/MG**, nos termos propostos na fundamentação deste voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1963433 - SP (2021/0313183-7)

RELATOR : **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA
CRIMINAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
INTERES. : GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS
DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS
TRIBUNAIS SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA
PÚBLICA
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR
PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR
PÚBLICO

VOTO-VOGAL

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Estão sob apreciação **dois temas repetitivos** de absoluta importância para a justiça criminal, que se conectam de maneira clara e importante: **Temas n. 1.154 e 1.241 do STJ.**

Para ressaltar a relevância dos Temas, registro que, segundo o Relatório Estatístico Anual de 2025 do Superior Tribunal de Justiça, "Tráfico de Drogas e Condutas Afins" foi o assunto mais demandado em todo o Tribunal no referido ano, com 46.236 processos assim categorizados. O número é quase três

vezes maior que o de processos autuados no segundo assunto mais comum nesta Corte Superior.

Ainda, do acervo de 67.680 processos existentes na 3ª Seção e nas 5ª e 6ª Turmas ao final do ano de 2025, 15.172 eram autuados sob esse mesmo tema. Isso significa que 32,81% dos feitos em andamento nos órgãos de jurisdição criminal do STJ referem-se ao Tráfico de Drogas. Nesses casos, a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é quase onipresente, sendo arguida em pedidos principais ou subsidiários submetidos diariamente a esta Corte.

Nesse expressivo cenário, é essencial recordar as inúmeras dificuldades – fáticas, teóricas e probatórias – para a correta aplicação de uma das mais impactantes causas de diminuição de pena da nossa legislação, capaz de transformar um crime hediondo com pena mínima de 5 anos de reclusão em um crime simples com pena mínima de 1 ano e 8 meses ao qual são aplicáveis diversas vantagens legais, viabilizando-se até mesmo a celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Ciente dessa realidade e da necessidade de uniformizar a aplicação da lei penal entre os diversos juízos e tribunais, sem, contudo, esvaziar a discricionariedade conferida por lei aos julgadores, que devem considerar aspectos sociais, subjetivos, regionais e o próprio contexto da atividade apurada para bem aplicarem a previsão normativa, passo a breves considerações com as quais pretendo contribuir com esta Colenda Seção na solução desses relevantes Temas Repetitivos.

No **Tema n. 1.241 do STJ**, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, o ponto em discussão foi assim delineado: “Possibilidade de utilização da quantidade e variedade das drogas apreendidas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”

Iniciado o julgamento dos paradigmas do referido Tema no dia 6/2/2025, o Ministro Ribeiro Dantas propôs as seguintes teses:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria.
2. A quantidade de droga, por si só, não afasta necessariamente a aplicação do redutor, mas pode servir de parâmetro para modulação da fração de diminuição.

Houve sustentação oral e pedido de vista antecipada do Ministro Rogerio Schietti, que apresentou seu voto em 12/2/2025, propondo as teses a seguir transcritas:

1. A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas preferencialmente na terceira fase da dosimetria da pena, para modular a fração de diminuição da pena, salvo quando não incidir na hipótese a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, oportunidade em que essa circunstância poderá ser aplicada na primeira etapa para aumentar a pena-base.
2. Caso a instância anterior haja afastado a incidência da minorante e valorado a natureza e a quantidade de drogas na primeira fase, mas o tribunal, em recurso da defesa, decida aplicar o redutor, deverá, se possível, deslocar a aplicação dessas circunstâncias para a terceira fase, a fim de modular a fração de diminuição, o que não configura *reformatio in pejus*.
3. Não configura *bis in idem* considerar a quantidade e a natureza de drogas como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, como elemento fático indicador de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Só haverá *bis in idem* se essa circunstância for usada, simultaneamente, para aumentar a pena-base e para modular a fração de redução da pena na terceira fase.
4. A apreensão de elevadíssima quantidade de drogas, em contexto de alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento, configura fundamento idôneo para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicar a dedicação do agente a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa.

Naquela assentada, detectou-se a **afinidade entre a questão discutida no Tema n. 1.241 e a do Tema n. 1.154**, que chegou à relatoria do Ministro Messod Azulay Neto após sua afetação, no qual foi delineada a seguinte questão: “Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.”

Assim, após a apresentação de voto-vista pelo Ministro Rogerio Schietti no Tema n. 1.241, o julgamento foi suspenso para posterior discussão conjunta com o Tema n. 1.154. Na mesma oportunidade, o Ministro Ribeiro Dantas suprimiu de seu voto o item 2 de sua proposta inicial.

Em seguida, no dia 14/5/2025, o Ministro Messod Azulay Neto apresentou voto abordando os Temas 1.241 e 1.154 em conjunto, com as

seguintes propostas de tese, em boa parte coincidentes com o que propôs o Ministro Rogerio Schietti:

1. A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas sempre de forma conjunta. Não é possível, portanto, realizar a aplicação separada como se fossem elementos autônomos;
2. A natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas preferencialmente na terceira fase da dosimetria da pena, para modular a fração de diminuição, salvo quando não incidir na hipótese a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, caso em que essa circunstância poderá ser aplicada na primeira etapa da dosimetria para aumentar a pena-base;
3. Caso a instância anterior tenha afastado a incidência da minorante e valorado a natureza e a quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, mas o tribunal, em recurso da defesa, decida aplicar o redutor, deverá, se possível, deslocar a aplicação dessa circunstância para a terceira fase, a fim de modular a fração de diminuição, o que não configura *reformatio in pejus*.
4. Não configura *bis in idem* considerar a quantidade e a natureza de drogas como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, como elemento fático indicador de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa para afastar a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Somente haverá *bis in idem* se essa circunstância for usada, simultaneamente, para aumentar a pena-base e para modular a fração de redução da pena na terceira fase.
5. A apreensão de elevada quantidade de drogas, o contexto de alto grau de profissionalismo, a sofisticada logística de transporte ou a complexa estrutura de armazenamento, conjunta ou separadamente consideradas, configuram fundamento idôneo para afastar a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicarem a dedicação do agente a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa.

Considero relevante esse pequeno registro histórico por razões que melhor evidenciarei adiante, e anoto que um ponto de especial atenção dessa discussão envolve a possibilidade de se considerar a quantidade e a natureza do entorpecente como um elemento contextual justificante para a não incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, ao mesmo tempo, como circunstância apta a exasperar a pena-base prevista no art. 42 da mesma Lei, o que passo a examinar.

Conforme bem referido nos votos já proferidos, ao apreciar o **Tema n. 712 da Repercussão Geral**, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte **tese**: “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.”

Acerca desse aspecto, o Ministro Messod Azulay afirmou:

Em sentido contrário, então, anoto, desde logo, que, no Tema 712, o Supremo não analisou a possibilidade de utilização simultânea da circunstância quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria e, na terceira fase, como fator de afastamento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343, 2006.

Estudando o paradigma do mencionado tema da repercussão geral, assim concluiu o Ministro Rogerio Schietti:

Igualmente, no julgamento da Repercussão Geral no ARE n. 666.334/AM (Tema n. 712), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, considerou que as circunstâncias da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (naquele caso, 162,57 g de cocaína) devem ser levadas em consideração em somente uma das fases do cálculo da pena, em observância à vedação do *bis in idem*.

No entanto, ressalto que o julgado mencionado também dizia respeito a caso em que se consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida na primeira etapa da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis e, na terceira fase, para justificar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 no patamar de 1/3, e não na fração máxima de 2/3.

[...]

Particularmente, considero que não configura *bis in idem* a utilização da quantidade de drogas apreendidas na primeira fase, para fins de exasperação da pena-base (conforme determina o próprio art. 42 da Lei n. 11.343/2006), e, novamente, na terceira, para impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da referida lei.

Isso porque a consideração da natureza e da quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, para fins de aumento da pena-base, justifica-se em razão da intensidade da lesão à saúde pública, bem jurídico penalmente tutelado nos crimes de tráfico de drogas e afins; já na terceira etapa, esses elementos são utilizados como dados fáticos para a aferição do envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de dedicação a atividades delituosas, isto é, o preenchimento de requisitos para a concessão de um benefício legal, o que é bastante diferente de promover dois aumentos na pena com base no mesmo fundamento fático.

De fato, no recurso objeto do **Tema n. 712 do STF**, ARE n. 666.334/AM, o caso concreto **não distinguiu** a possibilidade de a natureza e a quantidade de drogas serem um dos muitos elementos contextuais considerados para afastamento ou modulação da minorante.

Contudo, a possibilidade de a consideração **estrita** da natureza e da quantidade de entorpecente ser simultaneamente considerada para exasperar a

pena base e para definir a incidência da minorante ficou de fato vedada pelo Supremo Tribunal Federal.

Veja-se, a propósito, o que consta do voto condutor do agravo em recurso extraordinário em comento **paradigma do Tema n. 712 do STF**:

Cumpre destacar que, em sessão realizada no dia 19.12.2013, o Pleno do STF, ao julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do Min. Teori Zavaski, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa.

Na ocasião, ficou consignado que cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao *bis in idem*.

No presente caso, o Juiz de 1º grau, ao realizar a fixação da pena, levou em consideração a quantidade e a natureza da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria para elevar a pena do recorrente, o que é vedado nos termos da jurisprudência desta Corte.

À vista desses pressupostos, constata-se diferentes situações em que a natureza e a quantidade de entorpecente podem influenciar a dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas.

Em muitas situações, mais corriqueiras, massa e espécie da droga são referidas de modo exclusivo, impactando **por si só**s na exasperação da pena, hipóteses em que, como visto, não podem simultaneamente influir em mais de uma fase da dosimetria. Por outro lado, há circunstâncias em que a menção à quantidade e à natureza do material apreendido pode ser feita **em meio a outros elementos contextuais**, ou seja, associada, a um conjunto de fatores que afastam a caracterização de que o agente "se dedi[ca] às atividades criminosas" ou "integr[a] organização criminosa", segundo a literalidade do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Vale dizer: embora a quantidade e a natureza da droga sejam naturalmente ligadas à verificação do tipo de participação do agente na atividade ilícita, a caracterização do que prevê a lei para a correta consideração da causa de diminuição de pena em apreço frequentemente envolve aspectos adicionais, que não se limitam à observação do volume e do tipo de entorpecente, tais como **o contexto de logística, a distribuição, a forma de embalagem, o meio de armazenamento, a dificuldade de acesso ao entorpecente, a origem do**

fornecimento, o local das condutas apuradas, o grau de profissionalismo da empreitada, dentre outros.

Essa percepção – de que a quantidade e a natureza do entorpecente, embora mencionadas, por vezes apenas integram um contexto cujos aspectos afastam a caracterização de um tráfico de menor relevância – evita que todos os casos nos quais o afastamento da minorante esteja associado à natureza e à quantidade de drogas recebam a mesma pena, independentemente de qual seja essa quantidade. Afinal, a não incidência da minorante em geral deriva não da quantidade e da natureza do entorpecente, mas, sim, do conjunto de elementos deduzido do contexto, no qual se incluem aspectos relacionados ao material apreendido.

Tal conclusão evita, por exemplo, que se aplique a mesma pena para agentes que tenham transportado 2 ou 200 quilos de entorpecente ou a mesma quantidade de drogas que promovem efeitos e danos absolutamente discrepantes, permitindo que não apenas a quantidade e a natureza do material apreendido, mas também o disso se extrai para o contexto da conduta apurada, permitam que o julgador decida, fundamentadamente, pela incidência ou não da minorante e, se for o caso, pela correta fração a ser aplicada.

Nesse ponto, é importante mencionar que no Relatório do Parecer elaborado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, produzido antes da remessa do projeto de lei que originou a Lei n. 11.343/2006 ao Plenário daquela Casa Legislativa, que foi revisora na tramitação, constou o seguinte sobre a causa de diminuição em análise:

Não nos olvidamos da diferença existente entre pequenos e grandes traficantes. Por isso, mantivemos uma causa especial de diminuição da pena para o agente que seja primário e de bons antecedentes e cuja conduta se caracterize por ausência de habitualidade e caráter não profissional.

A redação legal final foi alcançada após proposição da então Deputada Federal Denise Frossard, substituindo-se a expressão "ausência de habitualidade e caráter não profissional" pela redação posteriormente sancionada: "desde que o agente [...] não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Há portanto, nítida intenção de distinguir o pequeno traficante que, além de eventual, não se ocupa de atividades criminosas e não possui nenhuma ligação com organização criminosa, sendo muitas vezes um dependente que

comercializa para sustentar o próprio vício, de modo a não sancioná-lo de maneira desproporcional.

Esse, aliás, é o sentido da justificativa apresentada como Exposição de Motivos do Projeto, assim redigida:

Outra questão tratada pelo projeto, e que em sendo objeto de profunda discussão, é a que se refere ao **pequeno traficante, de regra dependente, embora imputável, para quem sempre se exigiu tratamento mais benigno**. Não olvidando a importância do tema, e a necessidade de tratar de modo diferenciado os traficantes profissionais e ocasionais, prestigia estes o projeto com a possibilidade, submetida ao atendimento a requisitos rigoroso como convém, de redução das penas, ao mesmo tempo em que se determina sejam submetidos, nos estabelecimentos em que recolhidos, ao necessário tratamento. (Destaquei).

Ainda, deve-se mencionar que, no citado Parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi esclarecido que "A situação do mero informante, antes imprecisa na lei, passou a constituir crime independente [...], com pena de 2 a 6 anos". Ora, seria um contrassenso pensar que o legislador houvesse projetado para um informante do tráfico, tratado como não participante direto da conduta central, uma pena maior do que a prevista para o pequeno traficante, não fosse o caráter subsidiário e excepcional previsto para a conduta em sua forma minorada, marcada por simplória forma de realização.

Assim, antes de passar à síntese do que entendo oportuno apresentar como conclusão das reflexões que fiz sobre o tema, todas escudadas nos cuidadosos votos já apresentados, considero oportuno fazer um alerta às instâncias iniciais.

Parte das dificuldades encontradas no Superior Tribunal de Justiça ao apreciarmos as causas criminais deriva da falta de detalhamento quanto a elementos que, embora identificados por promotores, juízes e advogados, não foram suficientemente caracterizados na fundamentação das conclusões alcançadas.

Não raro, chegam a este Superior Tribunal processos nos quais havia determinadas circunstâncias que permearam as alegações das partes e o convencimento dos julgadores, mas que não foram transformados em fundamentação concreta e aferível pelas instâncias recursais.

Veja-se um exemplo, típico em processos que discutem o que se está a apreciar: ao sentenciar determinado agente pelo crime de tráfico, o julgador,

muitas vezes impressionado com o próprio volume de entorpecente, enfrenta de modo superficial as razões que o levaram a não aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Aquela fundamentação, contudo, por vezes referida pela primeira vez apenas na própria dosimetria da sentença, pode revelar-se insuficiente para sustentar a conclusão inicial por mera ausência de consideração sobre os elementos contextuais proibitivos de aplicação da minorante.

Da mesma forma, não é raro que defensores se vejam frustrados por tentar mostrar, nesta instância, a questão jurídica por ângulos não respaldados pelo que ficou consolidado como fatos processuais, impondo-se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ ante o descompasso entre elementos que se pretende considerar nas alegações recursais e o que ficou consolidado nos autos.

Sentenças bem fundamentadas, portanto, originam-se de denúncias adequadas, que abordam desde o início os elementos que justificam a não propositura da ação por tráfico privilegiado, inclusive afastando o oferecimento do acordo de não persecução penal; passarão por cuidadosas instruções, que examinem não apenas os elementos caracterizadores da traficância, mas também os aspectos capazes de influenciar na aplicação ou afastamento da causa de diminuição; e contarão com conclusões respaldadas em fatos bem apurados e submetidos ao contraditório, sem os quais a aplicação da lei penal não observará todos os históricos princípios que a informam.

A inobservância desses parâmetros continuará a compelir esta Corte Superior a promover anulações e reformas que, frequentemente, não decorrem de uma aplicação equivocada do direito material pelas instâncias de origem, mas da ausência de especificidade fática e de densidade na justificativa adotada, tornando inválidas ou insuficientes conclusões que, embora compatíveis com o caso concreto, não foram respaldadas em elementos que atendam ao dever de fundamentação das decisões judiciais na exigida pela hermenêutica do Direito Penal.

Passo, enfim, à apresentação de premissas que parecem servir de norte para as teses que serão fixadas, sintonizadas com grande parte das discussões já empreendidas:

a. Natureza e Quantidade vs. Contexto: A quantidade e a natureza das drogas, isoladamente, não podem fundamentar o afastamento da minorante. Contudo, o contexto da traficância, quando analisado sob o

prisma da estrutura, complexidade, profissionalismo, origem e local da conduta, pode justificar a não incidência do benefício.

b. Natureza e quantidade e fração de diminuição: os elementos acima mencionados, quando não considerados suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição especial de pena, poderão ser utilizados para definir a fração de incidência da minorante, sendo possível inclusive a consideração isolada da quantidade e da natureza nessa fase da pena, desde que realizada com fundamentação idônea e desde que não tenha havido exasperação da pena base em razão desses elementos.

c. Utilização preferencial na terceira fase: se a natureza e a quantidade de entorpecente, pela forma como referidas nos autos, só puderem ser utilizadas em uma das etapas estritamente matemáticas de fixação da pena, deverá ser privilegiada sua ponderação na apreciação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ou seja, a terceira fase da dosimetria.

d. Modificação da fase de ponderação em reforma que concede a aplicação do privilégio: nos casos em que se reforma a pena anteriormente fixada, reconhecendo-se a aplicação da minorante, a ponderação da natureza e da quantidade de drogas eventualmente realizada na primeira fase poderá ser transferida para a modulação da fração da circunstância minorante, operação que não gera prejuízo ao réu na pena total ao mesmo tempo em que contempla a incidência dos elementos fáticos apurados.

Por fim, apesar de as questões debatidas nos Temas n. 1.154 e 1.241 do STJ serem intimamente ligadas, proponho que a apresentação das teses seja feita em separado, cada uma vinculada à respectiva questão debatida e adstrita às discussões dos respectivos recursos paradigmas, o que poderá proporcionar **(i)** aplicação estrita dos dispositivos legais que regulam o julgamento dos recursos repetitivos; **(ii)** maior precisão na compreensão da comunidade jurídica e da sociedade sobre as conclusões; **(iii)** facilidade na aplicação separada de cada questão, porquanto frequentemente não são objeto de discussão conjunta; **(iv)** a manutenção das respectivas relatorias.

Assim, apresento à consideração dos estimados pares as seguintes **propostas de tese**, acompanhadas da sugestão de pequeno ajuste a ser realizado na "questão afetada" no Tema n. 1.154, o que passo a expor.

1.Proposição para o Tema n. 1.241 do STJ:

Questão afetada: Possibilidade de utilização da quantidade e variedade das drogas apreendidas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Tese proposta: A quantidade e a natureza dos entorpecentes devem ser avaliadas conjuntamente e podem ser ponderadas para modular a fração de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, inclusive quando a incidência da minorante for reconhecida no julgamento de recurso, devendo esse elemento, nessa hipótese, ser transportado da primeira para a terceira fase da dosimetria da pena, o que não configura *reformatio in pejus*.

2.Tema n. 1.154 do STJ

Questão afetada (com proposta de ajuste): Definir se a natureza e a quantidade da droga apreendida são suficientes para, por si sós, fundamentar a não incidência da minorante do tráfico prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

(Redação original da questão: Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.)

Tese proposta: O afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige fundamentação idônea e concreta, extraída dos autos. A natureza e a quantidade das drogas podem ser consideradas na análise do contexto que impede a incidência da causa de diminuição, observados elementos tais como o grau de profissionalismo, a estrutura de armazenamento, a logística de transporte, a origem do entorpecente e o local da conduta.

Passo à solução do caso concreto.

No caso dos autos, fixada a pena-base no mínimo legal, a minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão da quantidade, variedade e lesividade dos entorpecentes apreendidos - **"294 (duzentas e noventa e quatro) porções de crack, com peso aproximado de 227,62g (duzentos e vinte e sete gramas e sessenta e dois centigramas) e 01 (uma)**

porção da mesma droga, com peso aproximado de 22,18g (vinte e dois gramas e dezoito centigramas)" (fl. 183).

A propósito, constou do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (fls. 246-247, destaquei):

Por fim, na terceira etapa da dosimetria o Magistrado de origem não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e reconheceu a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas, assim fundamentando: "Tendo em vista a quantidade, variedade e lesividade dos entorpecentes apreendidos, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso, VI da Lei nº 11.343/06, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa" (fls. 189).

Observa-se que o Juiz sentenciante empregou a fundamentação pertinente a quantidade e variedade lesiva das drogas apreendidas", com base no artigo 42 da Lei de Drogas para afastar o benefício do redutor. **Realmente, não era mesmo o caso de se aplicar o referido benefício, uma vez que restou patenteada a efetiva dedicação do réu às atividades delitivas correspondentes ao tráfico de drogas pela soma de relevantes fatores: a quantidade de entorpecentes encontrados; o fato de ter sido apreendido tóxicos de natureza nefasta (cocaína); a forma como as drogas se apresentavam.**

Além disto, o réu não comprovou ocupação lícita. Afigura-se claro que apenas pessoa dedicada ao tráfico e às atividades criminosas, com convicção, tem sua conduta matizada pela conjugação de tantos elementos reveladores. E o fato de operar, além com drogas pesadas, de alto poder, como é a "cocaína", também indica sua profunda imersão no mundo do tráfico. Patente, pois, a dedicação às atividades criminosas por parte do acusado e pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que figura como impedimento legal à incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06.

Em complemento, veja-se que na sentença os elementos foram assim delineados (fls. 185-186):

Em seu interrogatório policial, o réu ARTHUR WALVIKE fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. **Em Juízo, confessa a prática do crime de tráfico, afirmando ter vindo à cidade para trazer a droga, que seria deixada na posse da adolescente.** Nega conhecer a pessoa de Vinícius. Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelo crime de tráfico. Isto porque, as declarações dos policiais militares somadas às do gerente do estabelecimento comercial, bem como a grande apreensão de entorpecentes

comprovam a autoria delitiva. Não obstante, o réu confessou a prática do tráfico de drogas.
Tem-se, ainda a **apreensão do caderno com anotações típicas do tráfico de drogas** (fls. 79/83), que foi indicado pelo réu, o que demonstra a prática criminosa contumaz.

A motivação do réu ao fazer o transporte da droga em ato típico de uma atividade organizada, realizando a conduta junto a uma adolescente e portando caderno com registro de operações comerciais, indica o acerto da conclusão pela não incidência do benefício legal, constatada a dedicação à atividade criminosa.

Ante o exposto, **nego provimento ao recurso especial** de ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1963433 - SP (2021/0313183-7)

RELATOR : **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA
CRIMINAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
INTERES. : GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA
PÚBLICA
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR
PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO

ADITAMENTO AO VOTO

1) Contexto e contornos da divergência

Como todos sabem e já está relatado nos autos, o julgamento cuida de dois temas na sistemática dos recursos repetitivos: 1154, de minha relatoria, e 1241, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, respectivamente, circunscritos às seguintes controvérsias: 1) “isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das

referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado"; e 2) "possibilidade de utilização da quantidade e variedade de drogas apreendidas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006".

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1241, decidiu, após a apresentação de voto-vista do Ministro Rogério Schietti Cruz – que, naquela oportunidade, em razão da correlação existente, avançava na matéria relativa ao tema 1154 –, suspender o julgamento para que a matéria fosse examinada em conjunto com a controvérsia relativa ao tema 1154, de minha relatoria.

Na sessão do dia 05 de junho de 2025, apresentei voto, manifestando minha adesão, quase integral, às propostas trazidas pelo Ministro Rogério Schietti, com pequenas alterações, especialmente em relação ao item 6.5, e com o acréscimo de um item (item 6.1) nos seguintes termos:

6.1) a natureza e quantidade de drogas devem ser valoradas sempre de forma conjunta. Não é possível, portanto, realizar a aplicação separada como se fossem elementos autônomos;

6.2) a natureza e a quantidade de drogas devem ser valoradas preferencialmente na terceira fase da dosimetria da pena, para modular a fração de diminuição, salvo quando não incidir na hipótese a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, caso em que essa circunstância poderá ser aplicada na primeira etapa da dosimetria para aumentar a pena-base;

6.3) caso a instância anterior tenha afastado a incidência da minorante e valorado a natureza e a quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, mas o tribunal, em recurso da defesa, decida aplicar o redutor, deverá, se possível, deslocar a aplicação dessa circunstância para a terceira fase, a fim de modular a fração de diminuição, o que não configura *reformatio in pejus*.

6.4) não configura *bis in idem* considerar a quantidade e a natureza de drogas como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, como elemento fático indicador de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa para afastar a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Somente haverá *bis in idem* se essa circunstância for usada, simultaneamente, para aumentar a pena-base e para modular a fração de redução da pena na terceira fase.

6.5) a apreensão de elevada quantidade de drogas, o contexto de alto grau de profissionalismo, a sofisticada logística de transporte ou a complexa estrutura de armazenamento, conjunta ou separadamente consideradas, configuram fundamento idôneo para afastar a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicarem a dedicação do agente a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa.

Após a apresentação do voto durante a sessão de 05 de junho de 2025, pediu vista o Ministro Rogério Schietti e, na última sessão do dia 05 de fevereiro de 2026, trouxe ao colegiado voto em que apresentou divergência parcial em relação à tese do item 6.5 com repercussão prática na solução de dois casos concretos afetados: os Recursos Especiais 1.963.433 e 1.964.296.

O Ministro vistor, em sua divergência, apresentou a seguinte redação para o item 6.5: “[a] apreensão de **elevadíssima** quantidade de drogas, **em contexto de alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento, configura fundamento idôneo para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicar a dedicação do agente a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa**”.

Diante da discordância, pedi vista regimental e submeto, nesta sessão, minha manifestação apenas em relação ao ponto divergente em aditamento ao voto proferido anteriormente.

Antes de mais nada, registro que, embora pontual – relativa apenas ao item 6.5 –, a divergência não se limita a uma questão meramente redacional. Muito pelo contrário, é substancial, tanto que altera a solução para dois casos concretos afetados neste julgamento.

De forma simples, a tese por mim apresentada, admite que o binômio natureza e quantidade afastem a causa de aumento do §4º do art. 33 da Lei 11.343, de 2006, e exemplifica – de modo, por tanto, não taxativo, mas de forma coordenada, alternativa e não vinculante a partir do termo “conjuntamente ou separadamente consideradas” – algumas hipóteses em que o afastamento do benefício legal, sem deixar de lado outras possíveis, seria possível na análise do caso concreto pelo juízo competente: elevada quantidade, alto grau de profissionalismo, sofisticada logística de transporte ou a complexa estrutura de armazenamento. São contextos extraídos dos casos concretos que chegam rotineiramente a este Tribunal Superior. Não significa, contudo, que são somente esses que existam e que não possa haver outros.

Por outro lado, a tese apresentada pelo Ministro Rogério Schietti, além de adotar um superlativo para um dos critérios – em vez de elevada, “elevadíssima” quantidade – vincula essa “elevadíssima” quantidade a dois contextos de apreensão específicos: “alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento”.

Estabelecidos os contornos da divergência, retomo, ainda neste primeiro momento da minha manifestação, uma discussão – que tenho tentado estabelecer na Corte, vide, por exemplo, divergência apresentada por ocasião do julgamento do tema 1262 – sobre a metodologia de formação das teses pela Terceira Seção.

Parece ser adequado que, na elaboração de teses vinculantes, o Colegiado tenha atenção aos casos concretos e aos limites da controvérsia em julgamento. O precedente deve, assim, indicar uma sumarização do passado, ou seja, daquilo que já foi julgado reiteradamente vezes pelo Tribunal, a partir das mesmas razões de decidir, e, igualmente, a partir do que constitui o objeto da controvérsia afetada. Não cabe, portanto, formulação de normas para o futuro desvinculadas dos julgamentos passados e fora dos limites do objeto controvertido.

Aliás, está aí um ponto que entendo muito problemático: o que deveria vincular na formação de um precedente? Sem a pretensão de entrar na profundidade que o tema possui na doutrina ou mesmo na academia, o transplante da sistemática de precedentes à realidade brasileira parece ter se dado sem ajustes ao desenho constitucional dos Tribunais Superiores ou traduções indispensáveis para um funcionamento adequado do instituto.

A ideia brasileira de precedentes tem gerado vinculação de teses nem sempre correspondentes aos casos julgados, bem como com a criação de teses nem sempre vinculativas, inclusive com a elaboração de nomenclaturas adjetivas, como precedentes “vinculantes” e precedentes “persuasivos”, o que, aparentemente, numa concepção original do instituto transplantado, não faria sentido. O precedente, numa acepção originária, deveria vincular pelas “razões de decidir” incidentes nos casos concretos – pelas teses centrais concretas que resolvem problemas jurídicos concretos –, e não por “dispositivo” elaborado criativamente para o futuro com utilização de elementos, por vezes, estranhos às controvérsias afetadas.

Obviamente, dada a sistemática comumente adotada, tenho feito, em respeito à colegialidade e não sem crítica, concessões, assim como o fiz, neste caso, para acompanhar o Ministro Schietti quase que na integralidade de seu voto vista. Todavia, entendo que, no ponto da divergência que se apresenta, com a proposta de vinculação de um contexto específico não previsto em lei, na minha visão, esta Corte extrapolaria sua função constitucional judiciária e usurparia o discurso legislativo.

Assim, entendo que seria possível, a partir das controvérsias afetadas, sim, a indicação de contextos em que a quantidade e natureza da droga podem afastar o redutor do §4º, desde que de forma exemplificativa (não taxativa) e alternativa (não vinculante).

O que vincula, portanto, é a interpretação de que a quantidade e natureza podem afastar a causa de diminuição de pena, como passo a explicar com mais detalhe.

2) A interpretação dos requisitos subjetivos do §4º do art. 33 da Lei 11.343, de 2006

Neste aditamento, retomo, rapidamente, a interpretação do §4º do art. 33 da Lei 11.343, de 2006.

Parto de um pressuposto básico da redação legislativa do dispositivo legal: a aplicação da figura privilegiada é exceção, e não regra. Depende da configuração de requisitos específicos e não poderia, ou não deveria, ser aplicada de forma irrestrita e como se fosse a regra geral.

Em relação a essa premissa, não parece haver divergência.

Resta, então, interpretar os requisitos subjetivos do §4º à luz desse pressuposto, isto é, como excepcionalidade legal, desde que presentes seus requisitos.

Como se sabe, o §4º estabelece dois requisitos positivos de ordem objetiva e outros dois negativos de natureza subjetiva. Consoante a redação do dispositivo, para incidência da causa de diminuição, deve o agente ser “primário” e de “bons antecedentes” (requisitos objetivos) e “não se dedicar a atividades criminosas” nem “integrar organização criminosa” (requisitos subjetivos).

A pergunta que fica é: por que os dois últimos requisitos são subjetivos? Não poderiam ser objetivos?

Muito embora pudessem ser objetivos ou objetiváveis, os requisitos da “não dedicação às atividades criminosas” e “não integração de organização criminosa”, da forma como colocada pelo legislador, a não ser que sejam inúteis, devem ser avaliados a partir do contexto específico de cada caso concreto porque não denotam enquadramentos clássicos de reincidência e ou necessidade de trânsito em julgado em crime de organização criminosa.

A aferição da “*não dedicação a atividades criminosas*” não pode consistir em avaliação que indique, semanticamente, reincidência ou maus antecedentes porque são elementos que já constituem, a *contrario sensu*, requisitos objetivos para aplicação da minorante (primariedade e bons antecedentes). Caso fosse interpretado de forma a se exigir comprovação por meio de condenação criminal transitada em julgado, o requisito não teria nenhuma razão de existência.

Igualmente, a inferência de “*não integrar organização criminosa*” não pode depender de condenação transitada em julgado pelo crime específico de organização criminosa, nos termos da Lei 12.850, de 2013, porque constituiria, da mesma maneira, mera repetição do requisito objetivo da primariedade e, portanto, também não teria razão de existência.

A interpretação desses requisitos subjetivos deve, então, obedecer a uma lógica contextual específica fático-probatória em cada caso concreto, que aponte para uma situação em que o agente não se dedica a atividade criminosa e não integra organização criminosa.

Teleologicamente, portanto, a norma leva, invariavelmente, à conclusão de que a minorante se destina ao traficante eventual, ao pequeno traficante, às pessoas não envolvidas, ainda que indiretamente, a organizações voltadas ao tráfico de drogas como meio de vida profissional. Repito, o benefício é aplicado como exceção, e não como regra.

Os contextos indicados pela tese proposta de minha relatoria, assim, indicam exemplos em que se afasta a ideia dessa eventualidade ou pequena traficância: mesmo sem elevadas quantidades, a sofisticação do armazenamento ou alto grau de profissionalismo no transporte podem, a meu ver, indicar que o agente integra organização criminosa ou, ao menos, dedica-se às atividades criminosas. Não se coaduna à finalidade do benefício admitir que pessoas naqueles contextos sejam consideradas não comprometidas com atividade de tráfico de drogas.

E lembro mais um aspecto que me parece relevantíssimo. O vetor não é, apenas, a “quantidade”, mas “quantidade e natureza”, de modo que, a depender da natureza, a avaliação das quantidades pode variar muito. A variedade da droga também pode ser um indicador de dedicação, a depender do caso concreto.

Enfim, neste ponto, parece contraditório afirmar a premissa de que o §4º cuida de uma excepcionalidade e, ao mesmo tempo, vincular essa exceção a um contexto estreito de não aplicação. Isso carrega em si a contradição: ao vincular, aprioristicamente, a um determinado cenário, a aplicação do redutor se torna a regra, não a exceção.

Seja como for, no meu entendimento, a aplicação da excepcionalidade do §4º depende de uma avaliação dos fatos e das provas de forma concreta pelo juízo imediato competente.

3) “Elevada” ou “elevadíssima”

A divergência sustenta que o termo “elevada” quantidade causaria insegurança jurídica e, por essa razão, sugere a alteração para o superlativo “elevadíssima” quantidade.

Com todas as vênias, não vejo diferença prática no anseio por “segurança jurídica”. Assim como o termo “elevada”, “elevadíssima”, também, não indica quantidade específica. A repercussão parece, por conseguinte, ser semelhante.

Ademais, o termo, seja “elevada” ou “elevadíssima”, assim como os outros, também são contextuais, isto é, passíveis de análise no caso concreto. Basta se imaginar a comparação entre uma apreensão de drogas em uma região de fronteira do país, com outra em uma pequena municipalidade. Certamente, a densificação jurídica para os termos a denotar altas quantidades varia em grande escala, de modo que o superlativo não parece trazer mais ou menos segurança jurídica para a interpretação do vetor “quantidade e natureza”.

O superlativo não denota característica objetiva.

E mais. De forma contrária ao entendimento divergente, vejo como muito problemática a vinculação da “elevadíssima” quantidade a um contexto específico pronto e acabado de “alto grau de profissionalismo e sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento”. Essa interpretação pode gerar cenários em que “elevadíssimas” apreensões levam à aplicação da causa de diminuição de pena. Como ficaria, por exemplo, a seguinte hipótese: dez toneladas de cocaína apreendidas sem, contudo, elementos que indicassem alto grau de profissionalismo e logística sofisticada ou estrutura complexa de armazenamento. Seria caso de aplicação do tráfico privilegiado?

4) Precedentes, casos concretos e jurisdição criminal: flexibilidade e capacidade de expansão

A jurisdição criminal se apresenta, por excelência, a partir de forma problemática e casuística, isto é, a partir do caso concreto, do fenômeno específico que se observa na realidade, ao qual se atribui um efeito jurídico-penal. Assim, apesar do esforço vinculativo da sistemática da repetitividade, não se pode ignorar a indispensabilidade de espaço de flexibilidade e possibilidade expansão para aplicador imediato na aplicação da tópica-contextual da tese jurídica firmada pela instância extraordinária.

A partir da ideia de imediação, tenho que os Tribunais Superiores devem se evitar a revisitação profunda da atividade probatória. De nada adiantaria, no nosso sistema acusatório, a afirmação do princípio da oralidade se os tribunais puderem vincular os

juízes a contextos fáticos-probatórios ou revistar amplamente a valoração probatória realizada sem, contudo, terem tido contato imediato com a produção da prova.

A conclusão, pois, é: o juízo competente, no exercício da valoração da prova, pode, a depender do contexto, deixar de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343, de 2006, com fundamento no binômio natureza e quantidade de droga, conferindo, no caso concreto, densidade aos conceitos abertos de “se dedicar às atividades criminosas” e “integrar organização criminosa”. Assim, a redação do item 6.5, objeto da divergência pontual, poderia ser mais simples e deixar o “contexto de densificação” a cargo do julgador imediato, juízo natural ordinário de avaliação de elementos de fato e de prova. Todavia, a tese, tenta, atendendo ao Colegiado, de forma exemplificativa e com base nos casos concretos cotidianamente enfrentados por este Tribunal Superior, apresentar fatores – repita-se exemplificativos – de motivos que poderiam caracterizar dedicação a atividades criminosas e participação em organizações criminosas e, por conseguinte, afastar o redutor de pena.

5) Conclusão

Adito, portanto, os votos relativos aos Temas 1154, de minha relatoria, 1241, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, mantendo a redação proposta para o item 6.5 e as respectivas conclusões para os casos concretos.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1963433 - SP (2021/0313183-7)

RELATOR : **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA
CRIMINAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
INTERES. : GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA PÚBLICA
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR
PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO

ADITAMENTO AO VOTO

Após a apresentação do voto-vogal do Ministro Og Fernandes, apresento novo aditamento para reiterar minha posição e esclarecer sua incompatibilidade com as propostas apresentadas pelos votos divergentes.

Muito embora seja louvável a tentativa de compatibilização dos entendimentos apresentada pelo Ministro Og Fernandes – procurando um ponto médio preocupado com a justificação das decisões que afastam, a partir do exame dos contextos concretos, o tráfico privilegiado –, entendo que, infelizmente, a divergência persiste.

Explico o porquê.

Da forma como proposta, minha posição, diferentemente do que se vinha sendo aplicado majoritariamente neste Superior Tribunal de Justiça, permite a assunção de que o vetor “quantidade” seja considerado **isoladamente** para afastamento do tráfico de drogas, independentemente da justificação de um contexto específico: quantidades

elevadas serviriam, assim, como vetor de afastamento autônomo do benefício legal. De forma oposta, as duas posições, do Ministro Rogério Schietti Cruz e Og Fernandes, na linha do que já vem sendo aplicado, não admitem que a quantidade, desvinculada de um contexto predeterminado, afaste o redutor.

Repito o exemplo que sempre me trouxe perplexidade: estressando o cenário apenas para mostrar o ponto, imaginem a apreensão de 10 toneladas de drogas (ou qualquer outra quantidade elevada de entorpecentes), sem que conste nos autos qualquer outro elemento contextual específico dedicação ou integração a organizações criminosas. Estaria justificada, nessa hipótese, a aplicação do §1º ou do §4º? Na proposta por mim apresentada, não há dúvida de que a elevada quantidade, por si só, indicaria que esse traficante não poderia ser considerado uma pessoa dissociada de dedicação de uma atividade criminosa ou que não tivesse nenhum envolvimento com a criminalidade organizada.

Em resumo, nessa perspectiva, quantidades elevadas de droga podem indicar sim que a pessoa, aprioristicamente, não é um pequeno traficante e, por conseguinte, não deveria ser beneficiário da causa de diminuição legal de pena.

Reitero. O §4º constitui exceção, e não regra, de modo que sua aplicação – e, portanto, inaplicabilidade da regra (§1º) –, depende de justificação, e não o contrário (a dependência de contexto específico justificado para não aplicação do privilégio).

Diante da incompatibilidade, mantenho minha posição.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1963433 - SP (2021/0313183-7)

RELATOR : **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA
CRIMINAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
INTERES. : GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA
PÚBLICA
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR
PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO

VOTO-VOGAL

Trata-se de recurso especial interposto por ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, proferido na Apelação Criminal n. 1500795-78.2019.8.26.0126, assim ementado (fl. 244):

APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória Materialidade e autoria comprovadas Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Condenação que se impunha Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada e a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VII da Lei de Drogas Pena-base fixada no mínimo legal - Incabível a aplicação do benefício contido no art. 33,

parágrafo 4º, da Lei de Drogas, pois comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes à traficância, bem como a quantidade e natureza das drogas apreendidas Descabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta - Incabível regime prisional diverso do fechado diante das peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena Causa de aumento pertinente a participação de adolescente configurada - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, a Defesa alega violação dos arts. 33, § 4º, e 42, da Lei n. 11.343/2006, bem como dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do Código Penal.

Sustentou, quanto à necessidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento dos entorpecentes não constituem, por si, elementos idôneos para excluir o benefício, devendo servir apenas para calibrar a fração de redução, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e que não há prova concreta de dedicação do agente a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

Pontuou que a fixação do regime mais gravoso que aquele previsto em lei pelo *quantum* da pena imposta, não encontra-se idoneamente fundamento e, portanto, colide com as regras estabelecidas pelas Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

Ao final, pugnou pela aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas na fração máxima (2/3), com a consequente redução da pena, adequação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Contrarrazões às fls. 279-293.

O recurso foi admitido (fl. 296).

Por acórdão de 03.05.2022, o feito foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos, delimitando-se a seguinte controvérsia: *Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.* (fl. 332).

Pois bem.

O recurso especial atende os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No caso, o acusado foi condenado como incurso nos arts. 33, *caput*, c/c 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente) à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em suma porque mantinha em depósito, para fins de tráfico, 294 (duzentas e noventa e quatro)

porções de crack, totalizando aproximadamente **227,62 g (duzentos e vinte e sete gramas e sessenta e dois centigramas)**, e mais 1 (uma) porção da mesma droga com cerca de **22,18 g (vinte e dois gramas e dezoito centigramas)**, atuando juntamente com adolescente.

Os dois temas repetitivos em julgamento (1154 e 1241) tratam de uma mesma questão: saber quando e como a natureza e a quantidade da droga apreendida podem influir na pena do tráfico, seja para modular a fração de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, seja para afastar por completo essa causa de diminuição.

A matéria envolve tensão entre dois valores legítimos: de um lado, a proporcionalidade, que exige tratamento mais severo ao traficante profissional; de outro, a segurança jurídica, que reclama critérios claros para institutos que afetam a liberdade. Equacionar esses valores, respeitando os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal, é o que se espera desta Seção.

Para melhor estruturar o voto, separo os pontos em capítulos.

I. A razão da previsão legal do tráfico privilegiado - art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006

A Lei 11.343/2006 foi concebida para corrigir um defeito da legislação anterior: a Lei 6.368/76 tratava com o mesmo rigor o grande e o pequeno traficantes, mesmo quando eventual. A exposição de motivos é expressa: havia necessidade de “*tratar de modo diferenciado os traficantes profissionais e ocasionais*”. A minorante do § 4º nasceu dessa exigência de proporcionalidade, que consubstancia materialização do devido processo legal substancial.

O dispositivo foi estruturado em requisitos cumulativos. Dois deles são deliberadamente subjetivos: a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa. Se esses requisitos dependessem de condenação transitada em julgado, seriam idênticos, na prática, ao requisito da primariedade, já previsto no mesmo artigo. Não teriam razão de existir como requisitos autônomos, sendo certa a conclusão que o legislador não se utiliza de palavras inúteis e vans (*lex non frustra loquitur*).

A opção legislativa foi clara: atribuir ao juiz do caso concreto a tarefa de verificar, pelo conjunto das provas, se o réu se dedica ao crime ou integra organização criminosa. Estreitar artificialmente esses conceitos equivale a suprimir normas que o legislador decidiu manter.

II. Onde valorar a quantidade e a natureza da droga

O art. 42 da Lei 11.343/2006 determina que o juiz considere, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal, a **natureza e a quantidade**

da droga. A regra é obrigatória. O que ela não define é em qual fase da dosimetria essa consideração deve ocorrer.

A solução decorre do princípio da especialidade: quando presente a minorante do §4º, a terceira fase é a sede própria para absorver esse vetor, pois nela se modula a fração de redução específica do tráfico privilegiado. Quando a minorante não incidir, por não estarem preenchidos os requisitos, o vetor migra para a primeira fase, onde serve para exasperar a pena-base.

Natureza e quantidade formam vetor único. Não é possível fracioná-lo — usar a natureza na primeira fase e a quantidade na terceira, por exemplo. Essa fratura representaria dupla valoração do mesmo dado fático.

III. *Bis in idem* e os limites do Tema 712 do STF

O Tema de Repercussão Geral n. 712 do Supremo Tribunal Federal fixou tese sem ressalvas: *“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.”*

III.1. O que essa tese veda

A expressão *“levadas em consideração apenas em uma das fases”* refere-se à utilização do binômio como circunstância dosimétrica - isto é, como elemento que incide sobre a operação aritmética de cálculo da pena. Se o binômio foi usado na primeira fase para exasperar a pena-base, não pode ser usado na terceira fase para modular a fração redutora. Esse é o comando vinculante e deve ser integralmente observado.

Em aplicação ao tema vinculante em questão, conclui-se que a natureza e quantidade formam vetor único. A título exemplificativo, não é possível fracioná-lo, utilizando a natureza da droga para majorar a pena-base e, na etapa dosimétrica derradeira, modular a fração da minorante do tráfico privilegiado. Essa fratura representaria dupla valoração do mesmo dado fático.

Os temas de repercussão geral, na lógica instituída pela Emenda Constitucional n. 45/2004, têm formulação abstrata e eficácia sistêmica. O enunciado do Tema 712 não contém modulações ou ressalvas que autorizem distinções quanto à finalidade da valoração. A vedação é ampla no que diz respeito à incidência dosimétrica.

III.2. O que essa tese não abrange

Uma questão diversa, que o Tema 712 não enfrentou, é saber se a quantidade de droga pode ser considerada como elemento de prova para verificar se o réu preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas.

A distinção é precisa e opera em planos diferentes. Valorar o binômio como circunstância dosimétrica significa usá-lo como fundamento de operação aritmética sobre

a pena: exasperar a base, fixar regime, modular fração. É o que o Tema 712 veda em mais de uma fase. Coisa diversa é considerar a quantidade para aferir se o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Essa operação é de natureza probatória, não dosimétrica. Não se trata de “*cálculo da pena*”, mas de verificação de pressuposto de incidência de norma penal.

Essa formulação preserva a autoridade do Tema 712 - porque não admite dupla valoração dosimétrica - e, ao mesmo tempo, não retira do juiz a possibilidade de valorar o acervo probatório em sua totalidade ao examinar os requisitos do §4º. Impedir o juiz de considerar a quantidade de droga para avaliar se o réu se dedica ao crime seria resultado incompatível com o princípio do livre convencimento motivado e a individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88).

IV. Quando a minorante pode ser afastada

IV.1. A quantidade expressiva como indicador de dedicação ao crime

A quantidade de droga, sem qualquer fundamentação, não afasta automaticamente a minorante. Isso decorre da própria estrutura do §4º: os requisitos obstatórios são a dedicação a atividades criminosas e a integração a organização criminosa. A simples apreensão de volume expressivo não comprova, por si só e sem motivação, nenhum desses elementos.

Entretanto, a quantidade realmente expressiva de droga constitui indicador probatório relevante da dedicação do agente à atividade criminosa. A razão é objetiva: a dinâmica econômica do narcótráfico opera por confiança e hierarquia. O volume elevado de mercadoria ilícita, que representa alto valor econômico e alto risco penal, não é confiado a agentes eventuais, sem vínculos estáveis com a atividade. Quanto maior o volume, maior a confiança depositada e, por consequência, mais profunda a inserção do agente na estrutura do tráfico.

Essa inferência não é presunção absoluta. É raciocínio probatório legítimo, passível de contraprova. O réu pode demonstrar que, apesar do volume apreendido, sua participação foi eventual e desvinculada de estrutura criminosa. O que não se pode admitir é que o juiz seja impedido de extrair, da quantidade expressiva, a conclusão de que o agente se dedica ao crime, quando as circunstâncias do caso assim indicarem.

IV.2. Elementos contextuais: alternativos e exemplificativos

Além da quantidade, outros elementos do caso concreto podem fundamentar a conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização: logística sofisticada de transporte, estrutura de armazenamento, variedade das substâncias apreendidas, profissionalismo na operação.

Esses indicadores devem ser tratados como alternativos, não cumulativos. Cada um deles, por si mesmo, pode ser apto a demonstrar que o agente não é o traficante eventual que o §4º visa diferenciar. Exigir a presença simultânea de vários deles criaria, na prática, um padrão probatório mais elevado do que aquele que a lei estabeleceu para os conceitos abertos do dispositivo legal em questão.

A indicação desses contextos é exemplificativa. Não se trata de rol taxativo nem de lista vinculante. Trata-se de orientação aos juízos de instância sobre o tipo de elemento que, presente nos autos, autoriza a conclusão de que os requisitos do §4º não estão preenchidos.

IV.3. O controle pela fundamentação

Se os elementos são alternativos e a lista é exemplificativa, o controle da decisão recai sobre a fundamentação. O juiz que afasta a minorante precisa explicitar precisamente o raciocínio que vincula os elementos fáticos ao não preenchimento dos requisitos do §4º.

Quando o afastamento se apoia na quantidade, o julgador deve demonstrar, com dados concretos, por que aquele volume indica inserção estável do agente na cadeia do tráfico: a relação entre o volume apreendido e o padrão local de circulação de drogas, o valor econômico da mercadoria. Se a fundamentação for genérica - limitada à afirmação de que “a quantidade é grande”, o Tribunal deve reformar o *decisum*. Se for concreta e contextualizada, resiste ao controle recursal.

Essa exigência de fundamentação qualificada substitui, com vantagem, a exigência de cumulação de elementos: é mais flexível para o juiz de base e mais controlável pelos tribunais.

Segundo recente estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), intitulado *Critérios Objetivos No Processamento Criminal Por Tráfico De Drogas: Natureza E Quantidade De Drogas Apreendidas Nos Processos Dos Tribunais Estaduais De Justiça Comum*, embora tenham sido reconhecidas imprecisões nos números, concluiu-se que nos processos em curso nas Justiças Estaduais a média de apreensão por processo é de **85g (oitenta e cinco gramas)** de maconha e de **24g (vinte e quatro gramas)** de cocaína.

Note-se que essas quantitativos representam uma média de apreensão verificada em processo que não envolve o tráfico internacional, cuja competência é da Justiça Federal e, usualmente, envolvem quantidades bem maiores. Em outro relatório - *Perfil do Processado e Produção de Provas nas Ações Criminais Por Tráfico De Drogas* - o IPEA concluiu que nos feitos da competência federal, a média de apreensão é de **14,5kg (catorze**

quilos e quinhentos gramas) de *cannabis* e **6,6kg (seis quilos e seiscentos gramas)** de cocaína.

Assim, quando o afastamento do minorante do § 4º se apoia exclusivamente na quantidade, o caso concreto não pode relacionar à apreensão de gramas de drogas, mas sim de **vários quilos**, patamares que, sim, são aptos a autorizar a presunção de que o acusado possuía maior aproximação com a estrutura criminosa e, portanto, não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

É, outrossim, relevante deixar claro que o julgador, na análise do vetor quantitativo, deve se desapegar de seus conceitos pessoais, e analisar a **realidade fática do local onde exerça** sua jurisdição. De fato, enquanto é muito comum o tráfico de maiores quantidades de droga em regiões fronteiriças ou portuárias, menores volumes são geralmente encontrados em cidades do interior do Brasil.

IV.4. Natureza probatória do afastamento

Registro, por fim, que o afastamento da minorante nos termos aqui propostos não configura “*valoração do binômio na terceira fase da dosimetria*”. O que ocorre é operação de natureza diversa: o juiz conclui, pelo exame das provas, que o réu não preenche os requisitos normativos do §4º. A quantidade de droga funciona, nessa operação, como **elemento de convicção** apto a demonstrar a maior vinculação do acusado *se dedica regularmente a atividades criminosas* ou *integra organização criminosa*. Não é, repita-se, **circunstância dosimétrica** incidente sobre o cálculo da pena. Essa distinção preserva a compatibilidade com o Tema de Repercussão Geral n. 712 do Supremo Tribunal Federal.

V. O transportador eventual (“mula”)

É necessário, nesta oportunidade, abordar a situação do agente que atua como transportador eventual de drogas, vulgarmente denominado “*mula*”.

Na prática forense, consolidou-se a compreensão de que, caracterizada a condição de “mula”, o coeficiente redutor aplicável seria o mínimo legal de **1/6 (um sexto)**. Essa orientação, embora recorrente, não corresponde à sistemática do §4º e merece correção.

O art. 33, §4º, prevê redução de 1/6 a 2/3. A lei conferiu ao julgador margem de modulação para que a fração reflita, com precisão, o grau de envolvimento do agente com a atividade. A adequação da resposta penal, garantia prevista no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não se compatibiliza com critérios matemáticos fixados de antemão.

O transportador eventual pode apresentar graus muito diversos de envolvimento com a atividade. Há desde o agente aliciado uma única vez, sem qualquer conhecimento prévio da estrutura criminosa, até aquele que, embora formalmente na

condição de transportador, realiza viagens com frequência e mantém vínculo estável com o fornecedor. Entre esses extremos, há uma gama de situações que a fração variada de 1/6 a 2/3 foi desenhada para acomodar.

Caberá ao julgador, portanto, considerar: o grau de envolvimento do transportador com o proprietário da droga; a extensão do trajeto a ser cumprido; a quantidade e a natureza do entorpecente transportado; a existência ou não de remuneração e seu patamar; e outras variáveis concretas que permitam calibrar a fração redutora ao caso específico.

A simples condição de “mula”, por si só, não determina a aplicação automática do patamar mínimo de 1/6, nem impede, conforme as circunstâncias, a aplicação de frações mais elevadas ou mesmo o próprio afastamento da minorante, quando o conjunto probatório demonstrar que o agente, a despeito de sua função de transporte, mantém dedicação estável à atividade criminosa.

VI. Conclusão e teses propostas

Feitas essas considerações, **acompanho integralmente** o ministro relator quanto à proposta de redação dos teses dos Temas Repetitivos n. 1154 e 1241.

VI - Solução do caso concreto

Na solução do caso concreto, acompanho integralmente os fundamentos esposados pelo *em. Relator* para negar provimento ao recurso especial.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do ministro relator, a fim de negar provimento ao recurso especial e aderir à proposta de tese repetitiva firmada na sessão de 18 de junho de 2026.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO**

Número Registro: 2021/0313183-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.963.433 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 15007957820198260126

PAUTA: 05/03/2026

JULGADO: 05/03/2026

RelatorExmo. Sr. Ministro **MESSOD AZULAY NETO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário

Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA : MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
INTERES. : GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR PÚBLICO
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA PÚBLICA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após a renovação das sustentações orais e apresentação do voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, do voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz e do voto vogal do Sr. Ministro Og Fernandes, a Terceira Seção deliberou pela suspensão do julgamento para definição consensual da tese nos Temas Repetitivos n. 1.241 e 1.154, com sua oportuna proclamação e julgamento do caso concreto.

Aguardam a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Ausente, justificadamente, nessa assentada, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54216449416561865@

2021/0313183-7 - REsp 1963433

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO**

Número Registro: 2021/0313183-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.963.433 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

C54216449416561818615@ 2021/0313183-7 - REsp 1963433

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO**

Número Registro: 2021/0313183-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.963.433 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 15007957820198260126

PAUTA: 05/03/2026

JULGADO: 18/06/2026

RelatorExmo. Sr. Ministro **MESSOD AZULAY NETO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário

Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ARTHUR WALVIKE DE ASSIS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA : MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS - SP420671
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES. : ANACRIM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
INTERES. : GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO
RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
EDUARDO ABRAÃO - DEFENSOR PÚBLICO
PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINE - DEFENSOR PÚBLICO
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - DEFENSORA PÚBLICA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Retomado o julgamento, A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial e fixou a seguinte tese quanto aos Temas Repetitivos n. 1241 e n. 1154: "A apreensão de quantidade de drogas de tal modo expressiva que, por sua própria dimensão, seja incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno traficante, configura fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Fora dessa hipótese, a natureza e a quantidade das drogas podem afastar a minorante quando associadas a outros elementos do caso concreto - como alto grau de profissionalismo, sofisticada logística de transporte ou complexa estrutura de armazenamento -, dos quais se possa inferir, mediante fundamentação concreta, a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO**

Número Registro: 2021/0313183-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.963.433 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

C54216449416561818615@ 2021/0313183-7 - REsp 1963433